

LA TUTELA ECONÓMICA A FAVOR DEL AGENTE EN LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE AGENCIA: LÍNEAS Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

NEREA MONZÓN CARCELLER

Profesora Asociada Derecho Mercantil

Universidad de Murcia

RESUMEN

Este trabajo aborda las líneas y criterios interpretativos fijados por los tribunales para las indemnizaciones a favor del agente en caso de extinción del contrato de agencia, que difieren según el contrato se haya pactado por tiempo determinado o indefinido. La Ley del Contrato de Agencia contempla únicamente dos posibles indemnizaciones a favor del agente: la indemnización por clientela, que opera en ambos tipos de duración, y la indemnización de los daños y perjuicios por gastos realizados para la ejecución del contrato que no haya podido amortizar en el momento en que el empresario denuncie unilateralmente el contrato de duración indefinida. No obstante, los tribunales consideran indemnizables otros daños y perjuicios distintos a la extinción contractual haya ocasionado al agente en base al régimen general del Código Civil, así como para los contratos de duración indefinida, los causados por el incumplimiento por parte del empresario del plazo de preaviso legalmente previsto.

Palabras clave: agencia, agente, empresario, contrato, indemnización, clientela, daños y perjuicios, extinción, Directiva, preaviso, duración, inversiones, comisiones, remuneraciones, prescripción, distribución.

ECONOMIC PROTECTION IN FAVOUR OF THE AGENT IN THE TERMINATION OF THE AGENCY CONTRACT: JURISPRUDENTIAL LINES AND CRITERIA

NEREA MONZÓN CARCELLER

Associated Lecturer in Commercial Law

University of Murcia

ABSTRACT

This work addresses the lines and interpretative criteria established by the courts for compensation in favor of the agent in the event of termination of the agency contract, which differ depending on whether the contract is agreed for a fixed or indefinite period. The Agency Contract Law contemplates only two possible compensations in favor of the agent: compensation for clientele, which operates in both types of duration, and compensation for damages for expenses incurred for the execution of the contract that it has not been able to amortize at the moment in which the employer unilaterally denounces the contract of indefinite duration. In addition, the courts consider other damages and losses that the contractual termination has caused to the agent as compensable based on the general regime of the Civil Code, as well as, for contracts of indefinite duration, those caused by the employer's failure to comply with the deadline legally provided notice.

Keywords: agency, agent, entrepreneur, contract, compensation, clientele, damages, termination, Directive, notice, duration, investments, commissions, remuneration, prescription, distribution.

SUMARIO: I. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE AGENCIA Y POSIBLES INDEMNIZACIONES. 1. Duración del contrato. 2. Extinción del contrato con duración determinada. 3. Extinción del contrato por tiempo indefinido. Deber de preaviso. 4. Otras causas legales de extinción del contrato de agencia. 5. Posibles indemnizaciones a favor del agente en caso de extinción del contrato.— II. INDEMNIZACIÓN POR CLIENTELA. 1. Regulación legal. 2. La imposibilidad de pacto anticipado en perjuicio del agente y su interpretación por los tribunales. 3. La naturaleza, los requisitos y la cuantificación de la indemnización por clientela por parte de los tribunales. 3.1. Naturaleza y alcance. 3.2. Criterios para su aplicación. 3.3. Cuantificación de la indemnización por los tribunales teniendo en cuenta el límite máximo del art. 28.3 LCA. A) Consideraciones a valorar para la cuantificación. B) Sentencias que fijan la indemnización en el importe correspondiente al límite máximo del art. 28.3 LCA. C) Sentencias que moderan la indemnización fijándola por debajo del límite máximo del art. 28.3 LCA. 4. Especialidades en la agencia de vehículos.— III. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 1. Régimen legal. 2. Imposibilidad de pacto en perjuicio del agente. 3. La interpretación de la indemnización por daños y perjuicios del art. 29 LCA por parte de los tribunales. 4. La posible indemnización de otros daños y perjuicios que la extinción contractual ocasione al agente con arreglo al Código Civil.— IV. INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PREAVISO. 1. Indemnización equivalente a la media mensual de las retribuciones percibidas en los últimos cinco años (o período de duración contractual, si es inferior) multiplicada sobre los meses de preaviso omitidos. 2. Sentencias que conceden otros importes de indemnización. 3. No conceden indemnización por incumplimiento del deber de preaviso en plazo.— V. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA RECLAMACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR EL AGENTE.— VI. CONCLUSIONES.— VII. BIBLIOGRAFÍA.

I. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE AGENCIA Y POSIBLES INDEMNIZACIONES

El contrato de agencia se encuentra regulado en la *Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia* (en lo sucesivo, LCA), que incorporó al derecho español la *Directiva 86/653/CEE, de 18 de diciembre de 1986, sobre coordinación de los estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes*. Este contrato mercantil de colaboración se caracteriza por¹: (i) estabilidad, ya que es, *ministerio legis*, un contrato de tracto sucesivo, lo que lo diferencia de la comisión²; (ii) independencia del agente³, que tiene la condición de empresario mercantil o comerciante, lo que lo diferencia del representante de comercio o viajante —vinculado al empresario mediante relación laboral—⁴; (iii) exclusión,

¹ ALONSO ESPINOSA, F. J., *Derecho Mercantil de Contratos*, Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 80 a 82. Apunta este autor que, de faltar la nota de independencia, nos hallaríamos ante un representante de comercio o viajante encubierto, por lo que dejaría de aplicarse la LCA para quedar dicha relación sometida al régimen laboral.

² PALAU RAMÍREZ, F., en MARTÍNEZ SANZ, F., MONTEAGUDO, M. y PALAU RAMÍREZ, F., *Comentario a la Ley sobre el Contrato de Agencia*, Ed. Civitas, Madrid, 2000, pp. 46 y 47, apunta, además, como otras diferencias entre la agencia y la comisión, que el agente goza siempre de la condición de empresario o comerciante, que el agente únicamente está facultado para concluir el acto u operación de comercio si se pacta expresamente, así como que en la agencia cabe pactar la exclusividad de la relación con el empresario principal.

³ PALAU RAMÍREZ, F., en RUIZ PERIS, J. I. y MARTÍ MIRAVALLS, J. (dirs.), *Contratos de Distribución*, Ed. Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2018, p. 15, aclara que la nota de la independencia del agente no impide que la confianza desempeñe un papel fundamental en la configuración de la prestación del agente; en particular, la intransmisibilidad de su encargo sin autorización del agente, *inter vivos* y *mortis causa*.

⁴ ORTEGA PRIETO, E., *El Contrato de Agencia*, Ed. Deusto, Bilbao, 1993, pp. 13 y 14, critica que la LCA prescinda por completo de la normativa laboral, llevando a cabo una mercantilización de la actividad de mediación, que sustituya a la generalizada laboralización anterior.

Por su parte, PÉREZ CAMPOS, A. I., *Representación comercial: contrato de trabajo o agencia mercantil*, Ed. Laborum, Murcia, 2002, pp. 203 y ss., destaca la necesidad de delimitar correctamente las relaciones jurídicas de representación comercial reguladas por el Derecho del Trabajo (relaciones

salvo pacto en contrario, de la responsabilidad del agente por el buen fin, es decir, que no responde del cumplimiento de sus obligaciones por los terceros con los que contrate el agente por cuenta del empresario principal, y (iv) necesidad de constancia por escrito a solicitud de cualquiera de las partes.

1. Duración del contrato

El contrato de agencia puede celebrarse por tiempo determinado o indefinido, presumiéndose este último carácter en ausencia de pacto (art. 23 LCA).

Se ha apuntado que ni la Directiva ni la LCA contemplan la posibilidad de que las partes pacten un período de prueba, aunque se comparte la opinión de quienes sostienen que tal posibilidad no encuentra obstáculo legal si se limita al tiempo necesario para valorar las aptitudes⁵.

2. Extinción del contrato con duración determinada

De pactarse por tiempo determinado, el contrato se extingue al vencimiento del término convenido.

No obstante, si, llegado dicho vencimiento, la agencia se continuara ejecutando por ambas partes, se considera transformado en un contrato de duración indefinida (art. 24 LCA). En estos casos, a efectos del cálculo de la indemnización por clientela, se ha de sumar la duración de la última prórroga a la de los anteriores contratos entre las partes. En este sentido, cabe citar la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 309/2000, de 1 de abril (RJ 2000\2340)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, núm. 374/2016, de 22 de julio (AC 2016\1430)*.

En cambio, la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 206/2015, de 3 de junio (RJ 2015\4282)* consideró de duración determinada un contrato de agencia con duración inicial de seis meses, prorrogable tácitamente por periodos semestrales sucesivos, hasta un máximo de dieciocho meses.

entre el representante de comercio y su empresario) y las que se rigen por el Derecho Mercantil (relaciones jurídicas entre el agente y su empresario principal), con la consiguiente dualidad de jurisdicciones, advirtiendo de la falta de nitidez de la línea divisoria entre ambos tipos de relaciones jurídicas tanto en la legislación, como en la doctrina, la jurisprudencia y la realidad social. Como principal nota diferenciadora de ambas relaciones destaca este autor la posibilidad de que el agente sea una persona jurídica, posibilidad inexistente en la relación laboral especial del representante de comercio.

⁵ LARA GONZÁLEZ, R., *Las causas de extinción del contrato de agencia*, Ed. Civitas, Madrid, 1998, pp. 77 y 78. No obstante, advierte que para la doctrina francesa el pacto sobre el periodo de prueba habría de tenerse por no puesto.

La LCA no contempla la posible terminación anticipada de un contrato de duración determinada sin justa causa pero, de producirse tal supuesto, estaríamos ante un incumplimiento contractual por parte de quien instara la finalización del contrato, que conllevaría la obligación de indemnizar a la contraparte todos los daños y perjuicios ocasionados. De ser el empresario, la indemnización habría de comprender el lucro cesante por las comisiones dejadas de percibir por el vencimiento anticipado del contrato⁶. Si fuera el agente, no podría reclamar indemnización al empresario por la extinción contractual.

3. Extinción del contrato por tiempo indefinido. Deber de preaviso

Si, por el contrario, el contrato se hubiera pactado por tiempo indefinido (o por tiempo determinado transformado después en indefinido por continuación más allá del término previsto⁷), la agencia se extinguiría por denuncia unilateral de cualquiera de las partes, mediando preaviso por escrito.

El preaviso constituye una notificación de carácter recepticio, pues debe llegar a conocimiento del destinatario para surtir efectos, aunque no precisa ser aceptada por este⁸.

El plazo de preaviso ha de ser de un mes por cada año de vigencia del contrato con un máximo de seis meses. Si la duración contractual fuese inferior a un año, el preaviso mínimo será de un mes (art. 25.2 LCA)⁹. La LCA ha hecho uso de la facultad reconocida en la Directiva de ampliar de tres a seis meses el plazo máximo legal de preaviso, así como de prohibir que los plazos legales puedan reducirse por acuerdo entre las partes.

Ahora bien, si el contrato de agencia se extiende por más de un año, las fracciones no completadas no dan lugar a un mes más de preaviso (p. ej., si dura 29 meses y se cumplen dos anualidades, pero no la tercera, el preaviso es de dos meses, no de tres), pues hay que estar al tenor literal del art. 25.2 LCA, sin que se admitan interpretaciones extensivas, como acertadamente indica la *Sentencia de la Audiencia*

⁶ MOXICA ROMÁN, J., *La Ley del Contrato de Agencia*, Ed. Aranzadi, Navarra, 2001, p. 176. Este autor considera justas causas para la terminación anticipada, además de las previstas en el art. 26 LCA, la muerte o declaración de fallecimiento del agente.

⁷ En tal supuesto, para determinar el plazo de preaviso se sumará la duración que hubiera tenido el contrato por tiempo indefinido a la transcurrida desde que se produjo la transformación en contrato de duración indefinida (art. 25.5 LCA).

⁸ MOXICA ROMÁN, J., *est. cit.*, p. 177.

⁹ En contra del criterio mayoritario, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 5ª) núm. 925/2004, de 20 de julio (AC 2004\1605)*, para un contrato de agencia vigente durante 5 años y 10 meses, consideró que el plazo de preaviso correcto era de 6 meses (5 meses por cada uno de los cinco años completos de vigencia y 1 mes adicional por el período inferior al año). Por el contrario, la interpretación mayoritaria, basada en la dicción del precepto, considera que los períodos inferiores al año únicamente se tienen en cuenta para los contratos de duración inferior al año.

cia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) núm.432 /2024, de 13 de junio de 2024 (JUR\2024\264174).

Esos plazos legales pueden, en cambio, ser incrementados mediante pacto entre las partes, con la única condición de que el plazo de preaviso del agente no sea inferior al previsto para el preaviso del empresario (art. 25.3 LCA).

El final del plazo de preaviso coincidirá con el último día del mes, salvo pacto en contrario (art. 25.5 LCA).

El incumplimiento del plazo de preaviso por parte del empresario podría dar lugar, según los tribunales, a la indemnización al agente, como se analiza más adelante.

4. Otras causas legales de extinción del contrato de agencia

La Directiva no contempla, en cambio, otras causas de extinción sin necesidad de preaviso, cuestión que se deja en manos de los Estados miembros.

La LCA lo permite, tanto para el contrato de agencia con duración determinada como para el pactado por tiempo indefinido, en los siguientes casos (arts. 26 y 27):

- a) Incumplimiento total o parcial de sus obligaciones legales o contractuales por la otra parte, facultad resolutoria que, con carácter general, ya reconoce el art. 1124 del Código Civil.
- b) Declaración de concurso. Se contiene así para el contrato de agencia una excepción a la regla general del art. 156 del *Texto Refundido de la Ley Concursal*, conforme a la cual la declaración de concurso no es causa de resolución anticipada del contrato y se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de la otra parte de suspender o de modificar las obligaciones o los efectos del contrato, así como la facultad de resolución o la de extinción del contrato por la declaración de concurso de cualquiera de ellas o por la apertura de la fase de liquidación de la masa activa. Por tanto, en el contrato de agencia la declaración de concurso de una de las partes sí faculta para resolver anticipadamente el contrato sin necesidad de preaviso.

En ambos supuestos (a y b) el contrato se entiende finalizado cuando se produzca la recepción de la comunicación escrita en la que se especifique tanto la voluntad de dar por resuelto el contrato como la causa de extinción alegada (art. 26.2 LCA). Este criterio legal plantea problemas cuando el destinatario de la comunicación rehúsa su recibo, por lo que hubiera sido deseable contemplar en dicho precepto que también producirá efectos resolutorios el envío de una notificación fehaciente al domicilio fijado en el

contrato a efectos de notificaciones. Ante un supuesto en el que el agente había instado la resolución del contrato por incumplimiento por parte del empresario de la obligación de pago de las comisiones devengadas, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete (Sección 1ª) núm. 125/2015, de 29 de mayo (AC 2015\796)* consideró que, si bien la notificación determina el momento en que finaliza el contrato y constituye la prueba de la fecha en que concluyen sus efectos, no constituye un requisito de forma *ad solemnitatem* para que opere la resolución, de modo que, en ausencia de la misma, la interposición de demanda por el agente instando la resolución contractual debe considerarse como manifestación de la voluntad explícita del agente de dar por concluido el contrato y la fecha de emplazamiento de la parte demandada ha de entenderse como fecha de finalización de los efectos del contrato.

- c) Por muerte o declaración de fallecimiento del agente; no así por muerte o declaración de fallecimiento del empresario, sin perjuicio de la facultad de denuncia del contrato con duración indefinida por parte de sus sucesores con el preaviso que corresponda.

5. Posibles indemnizaciones a favor del agente en caso de extinción del contrato

La regulación de la LCA es de naturaleza imperativa (art. 3.1 LCA), salvo excepciones expresamente previstas. Esa imperatividad alcanza a las indemnizaciones que la ley reconoce al agente en caso de extinción contractual, algunas de las cuales difieren según la duración del contrato sea por tiempo determinado o indefinido.

La Exposición de Motivos de la LCA únicamente dedica su último párrafo a referirse a las indemnizaciones por extinción de contrato, limitándose a enumerarlas: «materia de singular relieve es la relativa a la indemnización debida al agente en caso de extinción del contrato. A fin de distinguir con claridad los diversos supuestos, se han regulado separadamente la indemnización por razón de clientela y la indemnización de daños y perjuicios».

Se ha destacado que el elemento característico del contrato de agencia es el reconocimiento al agente de su derecho a indemnización en el momento extintivo del contrato, reconociendo que la labor del agente no se agota con la promoción y, en su caso, conclusión de actos u operaciones de comercio para el empresario durante la vigencia del contrato, sino que su actuación también se encuentra encaminada a la creación y mantenimiento de una clientela permanente¹⁰.

¹⁰ MARTÍNEZ SANZ, F., *La indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión*, Ed. Civitas, Madrid, 1998, p. 59.

Tal regulación se contempla en los arts. 28 a 30 LCA, que prevén diversos supuestos en los que el agente tiene derecho a percibir una indemnización en caso de extinción del contrato de agencia:

- Indemnización por clientela, aplicable a la extinción del contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido.
- Indemnización por daños y perjuicios en los contratos por tiempo indefinido.

Tales indemnizaciones, en cambio, no procederán cuando el contrato se extinga por (i) incumplimiento de sus obligaciones por parte del agente¹¹; o (ii) cuando sea el agente el que denuncie el contrato, sin causa justificada, entendiéndose que existe tal causa cuando la denuncia se deba a circunstancias imputables al empresario¹² o a la jubilación¹³, invalidez o enfermedad del agente que no le permita razonablemente continuar con sus actividades¹⁴, o (iii) cuando el agente ceda a un tercero su posición contractual (con consentimiento del empresario)¹⁵.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª) núm. 197/2007, de 30 de marzo (AC 2007/957)* aclara que la exclusión de indemnización relativa a la cesión se refiere al agente cedente, no al cesionario que se subrogó en su posición, de modo que el contrato continúa tras esa novación modificativa pero, una vez extinguido el contrato de agencia con el cesionario, este último sí tendrá derecho a indemnización considerando al relación de agencia «como conjunto unitario, con lo que la actividad de captación de clientela realizada por el primer agente deberá ser evaluada en el momento de extinguirse totalmente lo que no ha sido sino una relación única, incrementando así la indemnización del agente sucesor».

Por tanto, no es que la cesión extinga el derecho a indemnización del agente, sino que el objeto de la cesión incluiría el eventual derecho a indemnización que,

¹¹ *Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 175/2010, de 8 de abril (RJ 2010/3529), núm. 1121/2008, de 3 de diciembre (RJ 2008/6944), núm. 1009/2005, de 16 de diciembre (RJ 2006/155), núm. 1248/2002, de 20 de diciembre (RJ 2002/10932).*

¹² La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 2ª) núm. 360/2004, de 5 de noviembre (AC 2004/2385)* consideró imputable al empresario que el agente se negase a adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias legales por haber fijado el empresario unas nuevas instalaciones cercanas al agente con el fin de asumir directamente en la zona la actividad del agente.

¹³ La jubilación del agente no le priva de su derecho a indemnización, según las *Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª) núm. 137/2013, de 15 de marzo (AC 2013/948)* y (*Sección 11ª) núm. 374/2009, de 2 de octubre (JUR 2010/21379)*, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 136/2005, de 2 de marzo (AC 2005/484)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 2ª) núm. 30/2013, de 30 de enero (JUR 2013/111293).*

Tampoco la jubilación constituye un criterio de valoración a la hora de cuantificar la indemnización, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) núm. 11/2006, de 2 de enero (JUR 2006/227985).*

¹⁴ *Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 5ª) núm. 271/2016, de 19 de julio (AC 2016/1555).*

¹⁵ El art. 30 LCA incorpora los mismos supuestos de excepción al derecho a la indemnización que recogía el art. 18 de la Directiva.

en su caso, pudiera corresponder por el trabajo realizado por el agente cedente, haciéndose efectiva dicha indemnización, si procede, una vez extinguido el contrato de agencia del cesionario.

A estos supuestos legales, la jurisprudencia añade otros de indemnización a favor del agente: el incumplimiento por parte del empresario del plazo de preaviso, en los casos de contrato con duración indeterminada y la indemnización de otros daños y perjuicios al amparo de los arts. 1.101 y 1.106 del Código Civil.

Por tanto, si el contrato se concertó por tiempo indefinido, la extinción contractual puede dar lugar a varias indemnizaciones distintas al agente: por clientela, por daños y perjuicios al no poder amortizar los gastos en que se ha incurrido para la ejecución del contrato, por otros daños y perjuicios indemnizables según el régimen general del Código Civil y por daños y perjuicios ocasionados por la falta de preaviso.

Por el contrario, la extinción del contrato por duración determinada únicamente puede dar lugar a una indemnización por clientela a favor del agente y, en su caso, a la indemnización de otros daños y perjuicios *ex* arts. 1.101 y 1.106 del Código Civil.

Corresponde al empresario probar los incumplimientos contractuales que imputa al agente, de modo que la ausencia o insuficiencia probatoria conlleva la obligación de indemnizar al agente, como aclaran la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 3ª) núm. 27/2000, de 27 de enero (AC 2000\289)* y la de la *Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) núm. 424/2012, de 28 de noviembre (AC 2013\810)*, criterio que, por otra parte, resulta de la aplicación del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Excluye la indemnización el incumplimiento de los objetivos de ventas impuestos contractualmente al agente, correspondiendo al empresario la carga de la prueba de tal incumplimiento del agente, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 4ª) núm. 57/2018, de 25 de enero (AC 2018\1118)*.

Sin embargo, sí se concede cuando la disminución de ventas que impide al agente alcanzar el objetivo mínimo viene motivada por la sustitución de los productos a vender por el agente, modificando los iniciales por otros con peor venta que hacían muy difícil la consecución de tales objetivos de ventas, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) núm. 601/2019, de 16 de diciembre (AC 2020\513)*. Es decir, no se considera incumplimiento del agente el descenso de las ventas cuando es debido a una modificación de condiciones introducida por el empresario.

También se excluye cuando el agente no ha podido obtener logros significativos en materia de aumento efectivo de ventas y desarrollo de clientes debido a la escasa duración contractual, la amplitud de territorios encomendados, ajenos al de la residencia del agente, y los problemas del agente para acceder a las muestras

y demás materiales necesarios para desarrollar su labor, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª) núm.423/2024, de 3 de junio de 2024 (JUR\2024\268320)*, que tampoco considera relevante estos efectos el que el agente incumpliese su deber de realizar viajes cada dos meses a las zonas de representación por carecer de entidad resolutoria del contrato y carecer el agente de los materiales necesarios por causa imputable al empresario principal.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª) núm.881/2024, de 20 de junio de 2024 (JUR\2024\303232)* tampoco consideró incumplimiento relevante la falta de asistencia del agente a las ferias del sector, por ser conveniente, pero no obligatoria.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo (Sección 1ª), núm. 346/2011, de 23 de junio (AC 2011\2010)* tampoco consideró incumplimiento excluyente del derecho a las indemnizaciones la falta de cumplimiento en algunos períodos de objetivos mínimos comerciales propuestos por el agente y que no constan pactados ni asumidos por el agente como vinculantes, sin que el empresario apercibiera en ningún momento al agente de la posible resolución contractual por tal motivo.

Por otro lado, tampoco priva de la indemnización por clientela el incumplimiento de la obligación de informar mensualmente¹⁶ sobre las visitas realizadas a los clientes, recogida en el clausulado general preconfigurado por el empresario, y nunca observada durante los años de duración contractual. Sí posee la naturaleza de incumplimiento contractual excluyente de la indemnización por clientela el que el agente omita informar de su participación en empresas competidoras, con la consiguiente infracción del deber de lealtad, lo que justifica la resolución contractual por el empresario, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 2ª) núm. 332/2017, de 29 de diciembre (AC 2017\1935)*.

También constituye incumplimiento relevante el que la hermana del agente, con quien se repartía la provincia de Alicante y el trabajo desempeñado por ambos se efectuaba bajo una única facturación, comenzase a prestar servicios para una empresa competidora de la zona con el conocimiento del agente y sin el conocimiento ni consentimiento del empresario, por lo que ello equivale a la realización de una actividad competitiva por el agente, excluyente de su derecho a indemnización por clientela o por daños y perjuicios, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 6ª) núm. 331/2012, de 20 de junio (AC 2012\2088)*.

El que el agente se dedique a desprestigiar al empresario frente a sus clientes es, asimismo, considerado incumplimiento relevante de su deber de lealtad y buena fe, excluyente de la indemnización a favor del agente, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª) núm. 904/2024, de 21 de junio (JUR\2024\367140)*.

¹⁶ La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6ª) núm. 290/2024, de 19 de julio (JUR\2024\409224)* tampoco consideró esencial el incumplimiento de la obligación de remitir informes mensuales exigidos en el contrato, cuyo cumplimiento interno nunca se exigió.

Incluso, en los casos de contrato con duración determinada con prórroga automática, salvo que alguna de las partes decida no continuarlo, si el agente es el que se opone a dicha prórroga, el TS ha declarado que pierde el derecho a la indemnización por clientela —salvo, lógicamente, que esa decisión estuviera basada en un incumplimiento contractual del empresario—, como indica la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 1020/2008, de 10 de noviembre (RJ 2008\5904)*.

Aunque no exista incumplimiento contractual por parte del agente, se considera justa causa a efectos de resolución por parte del empresario la incompatibilidad sobrevenida de un agente de seguros debida a modificaciones normativas o a la interpretación que de las mismas efectúa la Dirección General de Seguros, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) núm. 692/2017, de 9 noviembre (AC 2018\30)*.

Por el contrario, cuando es el agente el que insta la resolución contractual por circunstancias imputables al empresario, sí tiene derecho a las indemnizaciones de los arts. 28 y 29 LCA (*Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 670/2012, de 19 de noviembre (RJ 2013\903¹⁷)*). Entre tales circunstancias que justifican la resolución a instancias del agente se encuentra la modificación de las condiciones contractuales propuesta por el empresario y no aceptada por el agente. No obstante, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 6ª) núm. 196/2024, de 28 de junio (JUR\2024\366945)*, entendió que no justificaba a estos efectos la resolución contractual realizada por el agente el cambio de condiciones dado que, pese a venir impuestas por el empresario, con dicha modificación no se alteraba de manera relevante el contenido del contrato, al no disminuir los ingresos ni aumentar los gastos del agente.

En definitiva, los incumplimientos contractuales que carecen de suficiente entidad no deben dar lugar a la privación al agente de su derecho a indemnización.

A continuación, se analizan esos distintos supuestos de indemnización a favor del agente.

II. INDEMNIZACIÓN POR CLIENTELA

1. Regulación legal

El art. 28 LCA reconoce al agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario, o bien incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela

¹⁷ En el mismo sentido, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª) núm. 410/2017, de 2 de noviembre (AC 2018\669)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) núm. 374/2016, de 22 de julio (AC 2016\1430)* y *Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª) núm. 188/2016, de 30 de junio (AC 2016\1314)*.

preexistente, el derecho a ser indemnizado a la extinción del contrato si su actividad durante el mismo puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario. La cuantía debe fijarse equitativamente en función de criterios como la existencia de pactos de limitación de la competencia, la pérdida de comisiones o las demás circunstancias que concurran.

Dicha indemnización opera tanto en caso de extinción de contratos con duración determinada como indefinida o, incluso, cuando la extinción se produce por muerte o declaración de fallecimiento del agente.

No obstante, el art. 28.3 LCA fija un tope máximo a percibir por el agente al prever que la indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si fuese inferior¹⁸.

Aunque la duración del contrato de agencia sea superior, a efectos de cálculo de esta indemnización únicamente se tienen en cuenta los últimos cinco años de la relación entre las partes, como aclara la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) núm. 374/2016, de 22 de julio (AC 2016\1430)*.

La LCA reproduce la regulación contenida en el art. 17 de la Directiva, acogiéndose a la opción que en dicho precepto se daba de contemplar como circunstancia a tener en cuenta para el cálculo del importe de la indemnización la existencia de un pacto de exclusiva o cláusula de no competencia. La Directiva articulaba un doble sistema, puesto que concedía a los Estados miembros la facultad de optar entre la indemnización por clientela, basada en el modelo alemán, y la reparación del perjuicio ocasionado por la terminación contractual, inspirado en el Derecho francés¹⁹. La LCA optó por la primera de dichas opciones²⁰.

¹⁸ La remuneración del agente puede consistir en una cantidad fija, en una comisión (entendiendo por tal la remuneración variable según el volumen o el valor de la operación) o en la combinación de ambas. De no estar prevista en el contrato, el agente será retribuido de acuerdo con los usos de comercio del lugar donde ejerza su actividad o, en su defecto, la que sea razonable según las circunstancias concurrentes (art. 11 LCA). La comisión del agente se debe percibir, no solo cuando la operación se haya cerrado como consecuencia de la intervención del agente, sino también en el caso de los negocios de continuación, es decir, cuando se haya concluido con un cliente previamente captado por el agente. Además, si el agente tiene la exclusiva en una zona geográfica (o para un grupo determinado de personas), también percibirá comisión cuando se concluya una operación en esa zona o con persona perteneciente a ese grupo, pese a no haber intervenido (art. 12 LCA). Incluso, podrá cobrar comisión una vez finalizado el contrato cuando la operación se concluya en los tres meses siguientes a la extinción del contrato como consecuencia de la actividad del agente o cuando el pedido o encargo se recibiese antes de la extinción del contrato (art. 13.1 LCA). Por el contrario, no percibirá comisión cuando el negocio haya sido concluido por el trabajo de un agente anterior, salvo que, según las circunstancias existentes, fuera equitativo el reparto de la comisión entre agente saliente y entrante (art. 13.2 LCA).

¹⁹ MARTÍNEZ SANZ, F., *est. cit.*, pp. 89 y 90.

²⁰ LLOBREGAT HURTADO, M. L., *El Contrato de Agencia Mercantil*, Ed. J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1994, pp. 234 y ss., ha destacado que la legislación francesa pone el acento en la obligación de resarcimiento del agente para compensar el perjuicio producido con la extinción del contrato, siendo nulo cualquier pacto anticipado que cuantifique el montante de la indemnización o restrinja su

Dicha indemnización es compatible con las de daños y perjuicios por falta de preaviso o por falta de amortización de los gastos en que se ha incurrido en la ejecución del contrato o con la indemnización por daños y perjuicios conforme a los arts. 1101 y 1106 del Código Civil.

2. La imposibilidad de pacto anticipado en perjuicio del agente y su interpretación por los tribunales

Sin perjuicio del carácter imperativo de la regulación legal que recoge el art. 3.1 LCA²¹, el art. 19 de la Directiva ya imposibilitaba pactar, antes del vencimiento del contrato, una indemnización a favor del agente distinta de la legal en perjuicio de este. El objetivo de esa norma es proteger los intereses de los agentes comerciales frente a sus comitentes, así como promover la seguridad de las operaciones comerciales y facilitar el intercambio de mercancías entre los Estados miembros mediante la aproximación de sus sistemas jurídicos en materia de representación comercial, por lo que un empresario no puede eludir las citadas disposiciones mediante el simple juego de una cláusula de elección de la Ley aplicable según indica el *Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera)* en la *Sentencia de 23 marzo 2006 (TJCE 2006\88)*²².

Por tanto, únicamente son admisibles:

- (i) Los pactos que recojan una regulación más favorable para el agente, entendiendo por tal que sean superiores al máximo del art. 28.3 LCA²³. La naturaleza desfavorable o no del pacto para el agente comercial debe apreciarse en el momento en que las partes la pactan, de modo que, para la validez del pacto, debe saberse de antemano que no resultará perjudicial para el agente garantizando una indemnización igual o superior a la que resultaría de la aplicación de la norma legal, según la *Sentencia del*

alcance. Por su parte, el Derecho alemán y el italiano ya reconocían a favor del agente con anterioridad a la Directiva el derecho a percibir una indemnización tras la extinción del contrato.

²¹ PARJOLEA, A. D., «Comentario a la Sentencia del TS de 8 de octubre de 2010», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil* núm. 87/2011, Ed. Civitas, 2011, señala que se ha criticado doctrinalmente que el legislador español se haya excedido al atribuir el carácter imperativo a todos los preceptos de la LCA, salvo disposición expresa en contrario, dada la técnica más mesurada propia de la Directiva y de los ordenamientos más próximos. Se aparta así del principio general de autonomía de la voluntad del art. 1255 del Código Civil al considerar al agente como la parte débil del contrato, aunque advierte que la imperatividad produce a veces el efecto de colocar al agente en una posición de desventaja. Por ejemplo, en algunos casos al agente le resultaría más beneficioso tomar como referencia para el cálculo de la indemnización un período distinto al previsto en el art. 28.3 LCA, bien sea mayor o menor.

²² Caso Honyvem Informazioni Commerciali Srl contra Mariella De Zotti.

²³ *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 582/2010, de 8 de octubre (RJ 2010/7448)*, que declaró nulo un pacto que cuantificaba la indemnización «en un importe equivalente al 10 % de las comisiones devengadas por el /la Agente durante los dos últimos años de su actividad o durante el período de vigencia del Contrato, si el mismo fuera inferior al citado plazo de dos años».

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) de 23 marzo de 2006 (TJCE 2006\88). También concedió validez al pacto contractual del que resultaba una indemnización a favor del agente superior al límite legal la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª) núm. 288/2024, de 19 de abril de 2024 (JUR\2024\209211)*. Dado que la LCA pretende proteger al agente, cualquier pacto más favorable para este, debe ser admitido.

- (ii) Los pactos más desfavorables para el agente que se celebren una vez producida la extinción del contrato²⁴. Entre estos últimos, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) núm. 493/2018, de 22 de noviembre (AC 2018\1856)* admitió la validez como indemnización por clientela de un «pago de compensación único por rescisión de contrato» de 20.000 euros facturado tras la extinción del contrato de agencia, rechazando que correspondiese al agente cantidad adicional alguna. En la misma línea, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª) núm. 99/2018, de 6 de febrero (AC 2018\509)* no consideró nula la siguiente cláusula «ambas partes, por medio del presente acuerdo, se dan por satisfechas y pagadas, sin que tengan absolutamente nada que reclamarse la una a la otra por estas o similares conceptos relativos a su relación mercantil renunciando en este acto a interponer cuantas acciones legales pudieran convenirles», dado que el contrato se celebró el 1 de septiembre de 2014 y el acuerdo transaccional que incluía tal cláusula era de fecha 30 de marzo de 2015.

Partiendo del carácter imperativo de la regulación de la indemnización por clientela, basada en los arts. 19 de la Directiva y 3 LCA, la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera nulos los pactos contractuales de renuncia previa a la indemnización por clientela²⁵. La prohibición del art. 19 de la Directiva se

²⁴ PARJOLEA, A. D., «Comentario a la Sentencia del TS de 8 de octubre de 2010», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 87/2011, Ed. Civitas, 2011, apunta que la renuncia por parte del agente a la indemnización por clientela se puede llevar a la práctica tanto de forma expresa, como de forma tácita, dejando transcurrir el plazo de prescripción del art. 31 LCA. Y añade que no serían extensibles al subagente los efectos que sobre el agente ha desplegado su renuncia, por lo que resultaría procedente indemnizar por clientela al subagente incluso en aquellos casos en que el agente hubiera renunciado a la misma.

²⁵ *Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 19/2003, de 27 de enero (RJ 2003\1137), núm. 328/2003, de 7 de abril (RJ 2003\2951) y núm. 582/2010, de 8 de octubre (RJ 2010\7448).*

En el mismo sentido, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 3ª) núm. 314/2012, de 23 de octubre (JUR 2012\374906)* tiene por no puesta dicha cláusula contractual al implicar una renuncia anticipada a un derecho que aún no había nacido para el agente.

Y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6ª) núm. 344/2018, de 22 de noviembre (AC 2019\178)* declara la nulidad de un pacto reductor de la base sobre la cual calcular la fórmula del art. 28 LCA, excluyendo las comisiones derivadas de un gran número de clientes con los que se contrató en un punto de venta cerrado.

Por el contrario, no estima nula dicha cláusula para un contrato de agencia de seguros la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) núm. 172/2016, de 20 de julio*

extiende a cualquier pacto anticipado que limite el derecho del agente a obtener, finalizado el contrato y en caso de conflicto con su empresario, una indemnización que alcance la cuantía prevista en el art. 28 LCA o, que excluya por adelantado el juicio de procedencia equitativa previsto en dicho artículo. Por ello, ante una sucesión de contratos de agencia en la que se exigía al agente, para la firma del nuevo contrato, la firma de un acta de liquidación en la que las partes afirmaban no tener nada que reclamarse como consecuencia de la relación de agencia, acertadamente se ha señalado que la suscripción de tales documentos no impide tomar en consideración para el cálculo de la indemnización por clientela la suma del período de duración de todos los contratos encadenados, de modo que las actas de liquidación firmadas al concluir cada uno de ellos carecen de eficacia alguna para el cálculo de la indemnización por clientela, al vulnerar el carácter imperativo del art. 28 LCA, según la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 456/2013, de 27 de junio (RJ 2013\4982)*.

También ha considerado el Alto Tribunal que vulnera el carácter imperativo de la norma un pacto incluido en el contrato de agencia por el que se practicaba un descuento del 10 % sobre la indemnización resultante por clientela, limitando así la indemnización que corresponde al agente conforme a las previsiones legales, en la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 226/2020, de 1 de junio (RJ 2020\1349)*.

La posición mantenida por el TS en sus sentencias es que, si bien en España la LCA no traspone literalmente el art. 19 de la Directiva, su contenido esencial de norma prohibitiva sí ha sido trasladado al artículo 3.1 LCA mediante una fórmula imperativa, de modo que la aplicación del «principio de interpretación conforme», que impone resolver las dudas interpretativas de una norma nacional del modo más acorde con el Derecho de la Unión, permite concluir que en el art. 3.1 LCA se encuentra implícita la prohibición de pactos anticipados contenida en el artículo 19 de la Directiva²⁶.

Por su parte, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª) núm. 359/1999, de 9 de junio (AC 1999\6055)* declaró la nulidad de un pacto contractual por el que se indicaba que, en la comisión pactada, se incluía el 0,5 % destinado a compensar al actor de la indemnización por clientela que pudiera corresponderle.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 79/2020, de 22 de mayo (RJ 2021\916)* también declaró la nulidad de la cláusula siguiente: «la indemnización se compondrá de la cantidad equivalente a las co-

(AC 2016\1925), al no considerar de aplicación los arts. 25 a 29 LCA a esta modalidad especial de agencia, sujeta a normativa especial.

²⁶ SALAS CARCELLER, A., «Nulidad del pacto sobre importe de la indemnización a percibir por el agente en caso de terminación del contrato de agencia», *Aranzadi Doctrinal*, núm. 11/2011, Ed. Aranzadi, 2011.

misiones devengadas durante UN (1) mes por cada año de duración del presente contrato, con un máximo de OCHO (8) mensualidades, en aplicación del art. 6.3 del Código Civil».

Sí son admisibles, en cambio, los pactos que reconozcan al agente una indemnización superior a la legalmente prevista²⁷, aunque es difícil en la práctica que tenga lugar dicho pacto, al ser el agente la parte contractual más débil. En esa línea, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª) núm. 168/2023 de 24 marzo (JUR 2023\296153)* admitió la validez de la cláusula que tenía en cuenta para fijar el importe de la indemnización el equivalente a las comisiones percibidas por el agente en el último semestre, en el supuesto de no incumplimiento de las obligaciones contractuales, al resultar de su aplicación una indemnización por clientela superior a la legal.

Por su parte, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8ª), núm. 360/2009, de 28 de septiembre (JUR 2009\470612)* no consideró que vulnerase norma imperativa alguna la cláusula contractual en la que las partes pactaban la cuantía de esa indemnización al considerar que el art. 28.3 LCA establece máximos para el cálculo de la indemnización, por lo que si, con respeto a aquellos, pero no excluyendo el derecho, las partes, al amparo del art. 1255 del CC, fijan anticipadamente el importe de la indemnización, tal pacto debe desplegar sus efectos por no infringir norma imperativa alguna. Esa interpretación tiene difícil encaje en la jurisprudencia del TS y en la del TJUE.

3. La naturaleza, los requisitos y la cuantificación de la indemnización por clientela por parte de los tribunales

3.1. Naturaleza y alcance

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha destacado la función compensatoria de esta indemnización, presentándose de modo objetivable sobre los beneficios o ventajas que la actividad desplegada por el agente permanecerá exclusivamente en beneficio del empresario tras el cese del agente. Constituye una contraprestación por la actividad ya desarrollada por el agente, no una retribución diferida de prestaciones futuras. Actúa, por tanto, como instrumento específico de liquidación patrimonial de la relación contractual frente al marco general del resarcimiento contractual de los daños y perjuicios previsto en el Código Civil y que tiene un cauce específico en el art. 29 LCA. En este sentido, cabe citar la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 206/2015, de 3 junio (RJ 2015\4282)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 113/2018, de 6 de marzo (AC 2018\1160)*.

²⁷ *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 868/2010, de 10 de enero (RJ 2011\152)*.

Asimismo, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 5ª) de 16 de julio de 2004 (AC 2004, 1799)* añade que «la justificación de dicho derecho a indemnización nace indudablemente, no ya de un enriquecimiento del empresario, que en cualquier caso no se encuentra carente de causa, sino más bien del hecho de que lo que hasta el momento supone un enriquecimiento compartido por empresario y agente pasa exclusivamente a favor del primero, que viene a aprovechar, ahora en exclusiva, el fruto del esfuerzo compartido. Igualmente, la situación de hecho que ha de contemplarse para la procedencia de la indemnización por clientela ha de ser exclusivamente la vigente en el momento final del contrato con independencia de las fluctuaciones de clientela que puedan haber concurrido con anterioridad».

3.2. Criterios para su aplicación

Al tener el art. 28 LCA su origen en el art. 17 de la Directiva, resulta obligado tener en cuenta los criterios fijados por el *Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 26 marzo de 2009 (TJCE 2009, 71)*²⁸, que diferencia tres fases en su aplicación: (i) en la primera se deben calcular las ventajas o beneficios resultantes para el empresario de las operaciones con los clientes aportados por el agente comercial; (ii) en la segunda se ha de verificar si el importe obtenido en la fase anterior resulta equitativo, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso en cuestión, y (iii) en la tercera y última se debe contrastar el importe de la indemnización resultante respecto del tope o límite máximo previsto por la norma. Y deja claro que el art. 17 de la Directiva no permite que el derecho del agente a una indemnización esté limitado de oficio por el importe de las comisiones perdidas como consecuencia de la terminación de la relación contractual, aun cuando el valor de las ventajas conservadas por el comitente sea superior. En caso de que el empresario forme parte de un grupo de sociedades que trabaja con el mismo agente, cada empresario abonará exclusivamente las indemnizaciones que correspondan a esa sociedad, no las de otras sociedades del grupo.

No obstante, la *Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) de 23 marzo de 2006 (TJCE 2006\88)* ha destacado que, dado que el art. 17 de la Directiva no ofrece indicaciones detalladas respecto del método de cálculo de la indemnización, dentro del marco de la Directiva los Estados miembros pueden hacer uso de su margen de apreciación para elegir los métodos de cálculo de la indemnización con arreglo al criterio de equidad.

²⁸ Caso Turgay Senen contra Deustsche Tanoil Ombh. La Sentencia destaca que el art. 17 de la Directiva establece un sistema que permite a los Estados miembros optar entre dos soluciones que garanticen al agente comercial tras la terminación del contrato: bien una indemnización determinada de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 2 de dicho artículo, o bien la reparación del perjuicio de acuerdo con los criterios definidos en el apartado 3 del mismo. Los Estados miembros solo pueden hacer uso de su margen de apreciación para elegir los métodos de cálculo de dicha indemnización dentro del marco fijado.

De acuerdo con el marco comunitario, la LCA establece como requisitos para que se reconozca la indemnización, además de la extinción del contrato:

- 1) Aportación de nuevos clientes o incremento sensible de las operaciones con la clientela preexistente.

La carga de la prueba del incremento de clientela y de operaciones corresponde al agente²⁹ (art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Ante una transformación del sistema de ventas, pasando de un contrato de concesión o distribución a uno de agencia, en el que el agente alegaba haber aportado en bloque su clientela como distribuidor al contrato de agencia, el Tribunal Supremo, en *Sentencias de la Sala de lo Civil (Sección 1ª) núm. 565/2007, de 28 de mayo (RJ 2007\3605)* y *núm. 560/2007, de 25 de mayo (RJ 2007\3604)* negó que «la aportación en bloque» de clientela al celebrar el contrato pudiese ser tenida en cuenta a efectos de la indemnización por clientela del art. 28.1 LCA, debiendo, en su caso, reclamarse mediante el ejercicio de otras acciones, como las de indemnización de daños y perjuicios conforme al régimen general del Código Civil. Por el contrario, para el cálculo se ha de comparar la clientela en el momento inicial de la relación contractual y en el momento final³⁰. La misma Sentencia aclara que este requisito del incremento de clientela y/o de operaciones constituye una cuestión de hecho, únicamente revisable en casación por la vía del error de derecho en la apreciación de la prueba.

Si, tras esa comparación, se comprueba la disminución de clientela, no existe derecho a indemnización³¹, siendo indiferente que la pérdida de clientes no sea imputable al agente, sino a las circunstancias del mercado, como desaparición del pequeño comercio siendo sustituido por grandes superficies, según las *Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 1156/2004, de 30 de noviembre (RJ 2004/7901)* y *núm. 328/2003, de 7 de abril (RJ 2003\2951)*. Esta interpretación resulta lógica, pues el empresario no podrá aprovechar las ventajas de una clientela perdida, sea o no culpa del agente.

²⁹ *Sentencias de la Sala de lo Civil (Sección 1ª) núm. 102/2006, de 9 de febrero (RJ 2006\671), núm. 371/2009, de 2 de junio (RJ 2009\3366), núm. 57/2009, de 13 de febrero (RJ 2009\1490), núm. 1156/2004, de 30 de noviembre (RJ 2004/7901), núm. 328/2003, de 7 de abril (RJ 2003\2951), núm. 19/2003, de 27 de enero (RJ 2003\1137) y Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) núm. 335/2017, de 2 octubre (JUR 2017\275330).*

³⁰ En el mismo sentido, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 79/2020, de 22 de mayo (RJ 2021\916)* y de la *Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 3ª) núm. 211/2005, de 1 de febrero (JUR 2005\126148).*

³¹ En el mismo sentido, las *Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 79/2020, de 22 de mayo (RJ 2021\916)* y *(Sección 13ª) núm. 374/2016, de 22 de julio (AC 2016\1430)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª), núm. 109/2010, de 22 de febrero (AC 2010\534).*

No basta con la incorporación meramente nominal de nuevos clientes, sino que es preciso que efectúen pedidos al empresario por la intermediación del agente, es decir, que existan visos de permanencia de la clientela al momento de la extinción contractual, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (Sección 1ª) núm. 906/2024, de 22 de diciembre (JUR\2024\81048)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 3ª) núm. 324/2016, de 30 de diciembre (JUR 2017\64593)*.

En caso de sucesión de contratos de agencia de duración determinada, a efectos de medir el incremento de clientela, se ha de tener en cuenta toda la duración de la relación entre las partes, como acertadamente establece la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) núm. 374/2016, de 22 de julio (AC 2016\1430)*.

Igualmente, si, tras fallecer el agente, el negocio es continuado por su hija, subrogándose en la posición del padre, a efectos de cálculo de la indemnización por clientela se considera que existe un único contrato, por lo que los clientes captados por el padre se tienen en cuenta para el cálculo de la indemnización que como agente corresponde a la hija, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19ª), núm. 41/2004, de 23 de enero (JUR 2004\53182)*.

La *Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de abril de 2016 (TJCE 2016, 133)* ha puntualizado que el artículo 17.2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los clientes captados por un agente comercial con respecto a las mercancías cuya venta le haya sido encomendada por el empresario deben considerarse nuevos clientes, aun cuando esos clientes ya mantuviesen relaciones comerciales con el empresario con respecto a otras mercancías, si la venta de las primeras mercancías realizada por ese agente ha requerido establecer una relación comercial específica. Por tanto, si el agente vende nuevos productos a los clientes preexistentes del empresario, tales operaciones se han de tener en cuenta a efectos del cálculo de la indemnización por clientela.

En cambio, no se considera incremento de operaciones el incremento de la facturación debido al aumento acumulado del IPC durante la duración del contrato, según la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 1156/2004, de 30 de noviembre (RJ 2004/7901)*³².

Tampoco estimó el TS cumplido este requisito por parte de un agente que tenía encargado comprar mercancía para unos grandes almacenes en el mercado turco, al no ser equiparables los proveedores a los clientes, ya que no se genera un círculo de personas que satisfagan

³² En el mismo sentido, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 3ª) núm. 324/2016, de 30 de diciembre (JUR 2017\64593)*.

necesidades específicas sirviéndose de las prestaciones del empresario, con la estabilidad o asiduidad que permitan hablar de clientes del empresario, no del agente, según la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª)*, núm. 687/2010, de 15 de noviembre (RJ 2010\8871).

Por su parte, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 3ª)* núm. 324\2016, de 30 de diciembre (JUR 2017\64593) rechazó la indemnización a favor del agente por el escaso número de clientes captados por él y su insignificante volumen de ventas con respecto al total facturado por el empresario con anterioridad.

- 2) Que la actividad del agente pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario tras la extinción del contrato.

Si bien incumbe su prueba al agente que reclama la compensación, el requisito no permite imponer al agente la prueba plena de la efectividad de tales ventajas o del efectivo disfrute por el empresario, después de extinguido el contrato, de los clientes que aportó el agente, sino un «pronóstico razonable» en el momento inmediato posterior a la extinción contractual, acerca de cuál será el comportamiento probable de dicha clientela y, por tanto, de si es posible que el empresario continúe disfrutando o favoreciéndose de la misma³³.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª)* núm. 288/2009, de 10 de noviembre (AC 2010\273) aclara que la cuantía de la indemnización no se puede realizar únicamente en base al número de clientes aportados, con abstracción de las cantidades facturadas, sino en base a los verdaderos beneficios que los clientes aportados por el agente van a seguir produciendo al empresario en el futuro, es decir, que permanecen fieles a la empresa tras su cese. Se puede tener derecho a indemnización si un solo cliente continúa siéndolo de la empresa tras el cese del agente, si los beneficios que reporta son sustanciales, y, por el contrario, puede que continúen muchos clientes, pero con aportación muy escasa de beneficios e, incluso, con pérdidas (clientes morosos o insolventes, p. ej.), en cuyo caso no se generaría derecho a indemnización por clientela.

Ese pronóstico razonable queda confiado a la apreciación soberana del tribunal de instancia, no revisable en casación, salvo cuando la presunción

³³ *Sentencias de la Sala de lo Civil (Sección 1ª)* núm. 830/2009, de 4 de enero (RJ 2010\152), núm. 19/2003, de 27 de enero (RJ 2003\1137), núm. 102/2006, de 9 de febrero (RJ 2006\671), núm. 1296/2007, de 11 de diciembre (RJ 2007\8917), *Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (Sección 1ª)* núm. 906/2034, de 22 de diciembre (JUR 2024\81048), *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6ª)* núm. 461/2021, de 22 de diciembre (RJ 2022\350), *Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 2ª)* núm. 274/2016, de 28 de julio (AC 2017\660) y *Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 3ª)* núm. 324\2016, de 30 de diciembre (JUR 2017\64593).

de la instancia incida en arbitrariedad o irracionalidad, según la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª)*, núm. 328/2003, de 7 de abril (RJ 2003\2951).

El cese de la actividad de la empresa, aun no estando formalmente extinguida, impide, lógicamente, considerar que el empresario pueda continuar aprovechándose de la clientela generada por el agente, descartando la procedencia de la indemnización, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 8ª)* núm. 404/2019, de 18 de julio (AC 2019\1680). Sin embargo, la venta de la empresa no permite concluir la inexistencia de toda utilidad o ventaja mediante operaciones comerciales realizadas tras la extinción del contrato de agencia con los clientes aportados por el agente, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª)* núm. 7/2012, de 18 de enero (JUR 2012\41451).

Tampoco se da si el empresario —aseguradora— decide no prorrogar las pólizas de seguro de los clientes captados por el agente, aun tratándose de pólizas que gozaban de bonificaciones por no siniestralidad, según la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª)*, núm. 778/2005, de 7 de octubre (RJ 2005\7700³⁴).

En la misma línea, no existe tal pronóstico razonable de aprovechamiento de la clientela si el agente cierra los canales de comunicación que había puesto al servicio del empresario —un hotel—, pues los clientes del agente —mayoristas— derivan el negocio a los hoteles que les indica el agente, entre los que ya no se encontrará el empresario, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª)* núm. 543/2011, de 29 de noviembre (AC 2014\2173). Ni cuando el agente, al cesar, arrastra con él a los clientes aportados, disminuyendo en un 97 % los pedidos realizados por dicha clientela, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª)* núm. 108/2005, de 11 de febrero (AC 2005\418).

Tampoco en el caso de clientes que adquieren derechos de aprovechamiento por turno de alojamientos turísticos, pues la contratación no es algo periódico, sino que habitualmente se trata de una adquisición esporádica, aislada u ocasional, sin que las cuotas de mantenimiento que contribuyen al abono de los gastos de conservación y reposición de los apartamentos, de los elementos comunes, seguros y tributos puedan considerarse como una ventaja sustancial que seguirá obteniendo el empresario, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª)* núm. 390/2009, de 21 de octubre (AC 2009\2299).

³⁴ En cambio, condenó al empresario a indemnizar al antiguo agente con el pago de las comisiones que le corresponderían respecto de los clientes con los que, tras extinguir la póliza, volvió a celebrar una nueva, induciéndoles a depender de otro agente distinto, en base al deber de buena fe que impone al empresario el art. 10.1 LCA y a los arts. 1101 y 1106 del Código Civil.

- 3) Que resulte equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de la competencia³⁵, por la pérdida de comisiones o por las demás circunstancias que concurran³⁶.

Se debe diferenciar entre el pacto de exclusividad, que opera en el marco de un contrato de agencia vigente, y el pacto de limitación de la competencia, que encuentra su encaje temporal una vez extinguido el contrato³⁷.

Como destaca la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) núm. 33/2018, de 29 de enero (AC 2018\161)*, normalmente la equidad opera únicamente como elemento de reducción o disminución de la indemnización.

El juicio de equidad no permite en ningún caso que se supere el límite máximo del art. 28.3 LCA, ni suplir hipotéticas imprevisiones de los contratantes, como añadir una indemnización suplementaria «por contactos», según la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 868/2010, de 10 de enero (RJ 2011\152)*.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) núm. 322/2017, de 6 de julio (JUR 2017\244856)* aclara que la utilización del adverbio «equitativamente» por el art. 28 LCA insinúa que la indemnización ha de ser la razonable y justa, a la vista de las circunstancias concurrentes.

³⁵ El art. 20 LCA permite incluir en los contratos una cláusula de restricción o limitación de las actividades profesionales a desarrollar por el agente tras la extinción del contrato, cuya duración no podrá ser superior a dos años a contar desde la extinción del contrato de agencia (ni superior a un año si el contrato de agencia se hubiere pactado por un tiempo menor). Para su validez, dicho pacto habrá de formalizarse por escrito y únicamente podrá extenderse a la zona geográfica o a esta y al grupo de personas confiados al agente y únicamente podrá afectar a la clase de bienes o de servicios objeto del contrato de agencia (art. 21 LCA).

ALONSO SOTO, R., «Contenido del contrato de agencias», *Estudios y Comentarios Legislativos Civitas* (BIB\2007\3417) recuerda que se deben diferenciar dos tipos de pactos de no competencia: de un lado, los impuestos durante la vigencia del contrato, que imponen al agente la obligación de desarrollar su actividad en exclusiva para un solo empresario y, de otro lado, los que surten efecto tras su extinción, cuya duración no puede exceder de dos años (o un año, de ser inferior la duración contractual) y que está sujeto a los límites del art. 21 LCA.

³⁶ PARJOLEA, A. D., «Comentario a la Sentencia del TS de 8 de octubre de 2010», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 87/2011, Ed. Civitas, 2011, advierte que este requisito encierra una cierta inseguridad, por cuanto su concurrencia se deberá verificar en cada caso concreto, lo que requiere un juicio de pronóstico acerca de las perspectivas comerciales del establecimiento del empresario, que muchas veces será difícil de valorar en el plazo de un año que el art. 31 LCA concede al agente para reclamar la indemnización por clientela.

³⁷ LARA GONZÁLEZ, R., «Pacto de limitación de la competencia y extinción del contrato de agencia por incumplimiento del empresario», en AA.VV. (dirs.: CUÑAT EDO, V., MASSAGUER, J., ALONSO ESPINOSA, F. J., GALLEGU SÁNCHEZ, E.), *Estudios de Derecho Mercantil. Liber Amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 1144. Apunta este autor que, de extinguirse el contrato por incumplimiento de sus obligaciones por parte del empresario, el agente debería quedar liberado de su deber de no competencia, con lo que en tal caso el pacto habría devenido ineficaz (pp. 1160 y 1161).

La existencia de pacto de exclusiva se valora especialmente tanto a la hora de conceder la indemnización como para descartar rebajar el límite cuantitativo del art. 28.3 LCA, según aclara la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 2ª) núm. 58/2000, de 8 de febrero (AC 2000\576)*³⁸.

No obstante, el carácter exclusivo de la dedicación del agente es una de las circunstancias que cabe valorar, pero no constituye un presupuesto necesario³⁹.

Entre las circunstancias a tener en cuenta para la realización del juicio de equidad se encuentran la notoriedad, prestigio e implantación en el mercado de las marcas comercializadas⁴⁰ y la fuerte y relevante inversión del empresario en la publicidad de los productos, así como que, tras cesar la relación de agencia, el agente haya comenzado a desarrollar de forma inmediata la misma labor comercial para otra empresa del sector, lo que comporta el riesgo de pérdida de la clientela captada para el empresario anterior, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) núm. 33/2018, de 29 de enero (AC 2018\161)*.

Por otro lado, se ha apuntado que, en ocasiones, las circunstancias a tener en cuenta para el juicio de equidad tienen lugar tras la terminación del contrato, como las condiciones personales de los herederos del agente fallecido o su lejanía en el parentesco, o la actividad a desarrollar por el agente tras la extinción del contrato⁴¹.

Los citados requisitos tienen naturaleza acumulativa, no alternativa⁴².

³⁸ Salvo pacto en contrario, el agente no actúa con exclusividad, pudiendo intervenir como intermediario para varios empresarios, si bien llevando en tal caso una contabilidad independiente para cada uno de ellos (arts. 7 y 9.2.e) LCA). No obstante, si la actividad profesional de esos empresarios es igual o similar, pudiendo considerarse competitiva, necesita el consentimiento del empresario con quien primero hubiere contratado antes de contratar con posibles competidores —o del ejercicio por cuenta propia de tal actividad— (art. 7 LCA).

³⁹ *Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 737/2007, de 29 de junio (RJ 2007\5090), núm. 328/2003, de 7 de abril (RJ 2003\2951), núm. 19/2003, de 27 de enero (RJ 2003\1137) y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª) núm. 153/2006, de 22 de mayo (AC 2006\967)*.

⁴⁰ También defiende este criterio la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense (Sección 1ª) núm. 305/2017 de 31 de julio (AC 2017\1313) y la de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 3ª), núm. 211/2005, de 1 de febrero (JUR 2005\126148)*.

⁴¹ MARTÍNEZ SANZ, F., *est. cit.*, pp. 226 y ss.

⁴² *Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 79/2020, de 22 de mayo (RJ 2021\916) y núm. 113/2018, de 6 de marzo (AC 2018\1160) y Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) núm. 335/2017, de 2 de octubre (JUR 2017\275330)*.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora (Sección 1ª) núm. 216/2012, de 28 diciembre (AC 2013\626), en un supuesto en que el agente era una sociedad mercantil que fue disuelta, liquidada y extinguida, teniendo dos únicos socios con idéntica participación en el capital social que, al mismo tiempo, eran, además, administradores, consideró procedente que el empresario repartiese por mitad entre los socios la indemnización por clientela que debía corresponder a la extinta sociedad agente.

3.3. *Cuantificación de la indemnización por los tribunales teniendo en cuenta el límite máximo del art. 28.3 LCA*

A) Consideraciones a valorar para la cuantificación

Por lo que se refiere a la cuantificación de la indemnización, la fijación de la cuantía corresponde al juzgador de instancia y no es revisable en casación, salvo infracción de norma legal, error en la valoración de la prueba en la determinación de los datos fácticos, o cuando se incide en una notoria desmesura, en más o en menos, que supone un error palmario o arbitrariedad con conculcación del art. 24.1 CE, según aclara la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 328/2003, de 7 de abril (RJ 2003\2951)*.

Para su cálculo se han de tener en cuenta la totalidad de las cantidades percibidas por el agente en el desempeño de su actividad, es decir, el «conjunto retributivo» y no únicamente las comisiones fijas o porcentuales. El concepto de remuneración del art. 28 LCA es más amplio que el de comisión del art. 11 LCA. Por tanto, cuando el agente presta servicios adicionales a los clientes, como servicios *post* venta, dichas retribuciones del agente también se incluyen en el cálculo de la indemnización⁴³.

Al constituir una contraprestación por la actividad de promoción y, en su caso, conclusión de los actos u operaciones encomendadas, la remuneración a tener en cuenta para su cálculo no es el beneficio neto obtenido por el agente, sino la cantidad realmente percibida por la prestación realizada, es decir, la remuneración bruta. Por el contrario, no hay que incluir en su determinación: a) el reembolso de

⁴³ *Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 560/2022, de 11 de julio (RJ 2022\3815), núm. 528/2020, de 14 de octubre (RJ 2020\5234), núm. 505/2019, de 1 de octubre (RJ 2019\3799), núm. 506/2019, de 1 de octubre (RJ 2019\3772); Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 1ª), núm. 371/2019, de 15 de mayo (AC 2019\861), y las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª), núm. 113/2018, de 6 de marzo (AC 2018\1160) y (Sección 13ª) núm. 374/2016, de 22 de julio (AC 2016\1430).*

los gastos en que el agente hubiera incurrido en el desempeño del encargo⁴⁴; b) el IVA⁴⁵⁴⁶.

Existiendo, además de las comisiones por ventas propias del contrato de agencia, una remuneración del agente por servicios de almacenaje de productos y entrega a los clientes, la retribución percibida como almacenista y distribuidora a los clientes no se tiene en cuenta a efectos de cálculo de la indemnización por clientela, pues no se aprovechará el empresario del almacén del agente ni de sus medios logísticos, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete (Sección 1ª) núm. 39/2005, de 17 de febrero (JUR 2005\76703)*.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 7ª) núm. 135/2009, de 6 de marzo (JUR 2009\275288)* aclara acertadamente que su cálculo ha de hacerse con inclusión de las comisiones directas e indirectas —aquellas en las que las empresas realizan el pedido de los productos a fábrica y no al agente—, ya que ni la ley distingue entre unas y otras, ni pueden desvincularse las segundas de la labor del agente; de ahí que tales operaciones devenguen la comisión correspondiente, que ha de computarse para evaluar los rendimientos.

Como criterios a tener en cuenta para cuantificar la indemnización se señalan la extensa duración de la relación contractual, el incremento de la facturación y la entidad de la pérdida de comisiones, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 3ª) núm. 27/2000, de 27 de enero (AC 2000\289)*. Asimismo, otro factor a tener en cuenta es el índice de impagados existente en la clientela captada

⁴⁴ En el mismo sentido de excluir los gastos repercutidos del cómputo de la indemnización, cabe citar la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 174/2024, de 23 de febrero de 2024 (JUR\2024\127749)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 1ª) núm. 262/2016, de 10 de junio (JUR 2016/197840)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª) núm. 325\2015, de 9 de noviembre (AC 2015\1730)*.

⁴⁵ A favor de la sujeción a IVA de las indemnizaciones reconocidas en Sentencia a favor del agente, alegando consultas evacuadas a la Agencia Tributaria que obran en autos, destacan la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo (Sección 1ª), núm. 346/2011, de 23 de junio (AC 2011\2010)*, así como la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) núm. 344/2016, de 14 de junio (JUR 2016/186432)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 4ª) núm. 64/2009, de 18 de febrero (AC 2009\628)*, que advierte, no obstante, que el agente podrá deducir los gastos de abogado y procurador en que haya incurrido para obtener tales indemnizaciones. Por tanto, aunque para el cálculo de las retribuciones percibidas por el agente no se tenga en cuenta el IVA, una vez cuantificada la indemnización en sentencia, se habrá de incrementar con el IVA correspondiente, al suponer una nueva retribución a percibir por el agente por servicios ya prestados.

⁴⁶ En este sentido, la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 206/2015, de 3 de junio (RJ 2015\4282)*, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 79/2020, de 22 de mayo (RJ 2021\916)*, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª) núm. 188/2016, de 30 de junio (AC 2016\1314)*, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) núm. 335/2017, de 2 de octubre (JUR 2017\275330)*, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6ª) núm. 290/2024, de 19 de julio (JUR\2024\409224)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6ª) núm. 175/2020, de 28 de mayo (JUR 2020\208744)*.

por el agente, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3ª) núm. 442/2005, de 22 de octubre (JUR 2006\11078)*.

Asimismo, las *Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 113/2018, de 6 de marzo (AC 2018\1160) y núm. 197/2010, de 18 de febrero (JUR 2010\146314)* recuerdan que el artículo 28 de la LCA no excluye la indemnización, ni establece una reducción para el supuesto de que no existiera un pacto de prohibición de competencia *post* contractual. Los pactos de limitación de la competencia operan de futuro, es decir, una vez extinguida la relación contractual el agente no podrá durante un tiempo determinado operar con sus conocimientos o infraestructura en el mismo objeto o actividad, de forma que tal limitación se tiene en cuenta para determinar el mayor *quantum* indemnizatorio a los efectos de compensar la pérdida. Ahora bien, a falta de pacto de limitación de la competencia, si se acredita que los clientes obtenidos por el agente no han repercutido en provecho del empresario por haberlos hecho suyos el propio agente mediante la apertura del nuevo negocio, no habrá indemnización por tal clientela.

Las sentencias sobre la materia se dividen en dos grupos: las que hacen coincidir el importe de la indemnización con el del límite legal y las que moderan dicha cuantía realizando un juicio de equidad. Las del primer grupo, como se analiza a continuación, son más numerosas. No obstante, en muchos casos la concesión del máximo legal de indemnización se debe a dos factores: 1) el empresario demandado ha limitado su defensa a negar que exista obligación de indemnizar, sin incluir motivos de oposición subsidiarios que soliciten la rebaja de la cuantía reclamada por el actor, de considerar la sentencia procedente la indemnización; 2) no existen suficientes elementos probatorios que justifiquen moderar la indemnización en base a criterios objetivos, de modo que al juez o tribunal le resulta más fácil aplicar el límite legal que fundamentar la minoración de dicho importe.

Pese a ello, conceder como indemnización el máximo legal no debería ser la regla general, sino que, por el contrario, los tribunales deberían realizar el juicio de equidad previsto en el art. 28.1 LCA, cuantificando la indemnización en función de la concreta labor del agente y las ventajas sustanciales que la clientela por él captada pudiera continuar reportando ventajas para el empresario. Como dicho juicio de equidad requiere un esfuerzo adicional por parte del juez o tribunal cuando los abogados no proporcionan suficientes argumentos para la estimación parcial de la demanda, sería conveniente la modificación del art. 28 LCA con el fin de establecer criterios objetivos que facilitasen al juzgador la cuantificación de la indemnización en el máximo legal o aplicando reducciones porcentuales de la misma (p. ej., en función del porcentaje de clientela aumentada, del porcentaje de incremento de beneficio experimentado durante la vigencia del contrato, la existencia de pactos de limitación de competencia, el esfuerzo publicitario del empresario o de la marca, entre otros).

B) Sentencias que fijan la indemnización en el importe correspondiente al límite máximo del art. 28.3 LCA

Partiendo de tales criterios, son muy numerosas las sentencias de Audiencias Provinciales que fijan el *quantum* indemnizatorio en el límite del art. 28.3 LCA⁴⁷. No obstante, en algunos de los supuestos analizados en las citadas sentencias la parte demandada se limitó a rechazar la procedencia de la indemnización, sin discutir el importe reclamado en la demanda, para el caso en que el juez la considera-

⁴⁷ Entre ellas, cabe destacar las siguientes: *Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 6ª) núm. 186/2024, de 21 de junio (JUR\2024\300524)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja núm.265/2024, de 4 de junio de 2024 (JUR\2024\290218)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 3ª) núm. 1/2003, de 7 de enero (AC 2003\231)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 1ª) núm. 371/2019, de 15 de mayo (AC 2019\861)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 1ª) núm. 223/2016, de 5 de septiembre (AC 2016\238151)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 1ª) núm. 79/2012, de 24 de febrero (JUR 2011\149135)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) núm. 297/2018, de 24 de septiembre (AC 2018\1660)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª) núm. 316/2024, de 17 de junio (JUR\2024\265799)*, *Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 113/2018, de 6 de marzo (AC 2018\1160) y núm. 639/2005, de 10 de noviembre (JUR 2006\49378)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª) núm. 208/2015, de 18 de mayo (JUR 2015\157486)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19ª) núm. 30/2011, de 27 de enero (AC 2011\326)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19ª) núm. 253/2010, de 12 de mayo (AC 2010\291203)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª), de 13 de marzo de 2002 (AC 2002\986)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª) núm.881/2024, de 20 de junio de 2024 (JUR\2024\303232)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 8ª) núm.69/2024, de 15 de marzo de 2024 (JUR\2024\236082)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 4ª) núm. 57/2018, de 25 de enero (AC 2018\1118)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 5ª) núm. 191/2008, de 22 de mayo (AC 2013\752)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6ª) núm. 290/2024, de 19 de julio (JUR\2024\409224)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 5ª) núm. 214/2016, de 30 de mayo (AC 2016\2089)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 7ª) núm. 109/2013, de 7 de marzo (AC 2013\727)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) núm. 424/2012, de 28 de noviembre (AC 2013\810)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) núm. 369/2005, de 9 de septiembre (AC 2005\2249)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) núm. 335/2017, de 2 de octubre (JUR 2017\275330)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª), núm. 28/2008, de 21 de enero (AC 2008\796)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª) núm. 391/2024, de 26 de julio (JUR\2024\377025)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 3ª) núm. 331/2006, de 17 de julio (AC 2006\1532)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) núm. 11/2006, de 2 de enero (JUR 2006\227985)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 2ª) núm. 289/2005, de 26 de septiembre (JUR 2005\236687)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 2ª) núm. 216/2002, de 13 de diciembre (JUR 2003\35627)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7ª) núm. 604/2002, de 31 de octubre (AC 2003\111)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 2ª) núm. 4/2018, de 10 de enero (JUR 2018\64868)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) núm. 171/2014, de 4 de abril (JUR 2014\159819)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª) núm. 197/2007, de 30 de marzo (AC 2007\957)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 2ª) núm.245/2024, de 28 de junio de 2024 (JUR\2024\375885)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 2ª) núm. 370/2015, de 23 de diciembre (JUR 2016\31693)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3ª) núm. 109/2015, de 15 de abril (JUR 2015\126242)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3ª) núm. 130/2008, de 17 de marzo (AC 2008\1304)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 3ª) núm. 168/2013, de 18 de abril (AC 2014\739) o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 2ª) de 18 de enero de 2000 (AC 2000\23).*

se procedente, ni ofrecer al juez argumentos para realizar el juicio de equidad que moderase la indemnización, en su caso.

C) Sentencias que moderan la indemnización fijándola por debajo del límite máximo del art. 28.3 LCA

Por el contrario, también encontramos otras muchas sentencias de Audiencias Provinciales que, en aplicación del juicio de equidad, cuantifican la indemnización en un importe inferior al correspondiente al límite máximo legal.

Como criterios para moderar la indemnización, en tales sentencias se tienen en cuenta:

- El que la agente heredó la cartera de clientes de su padre, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19ª)*, núm. 41/2004, de 23 de enero (JUR 2004\53182,) para rebajar en un 10 % la indemnización máxima legal.
- La notoriedad de las marcas comercializadas y la importante inversión en publicidad, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª)* núm. 60/2012, de 27 de enero (JUR 2012/66046), para cuantificar la indemnización en el 80 % del máximo legal.
- La contribución del empresario a la captación de la clientela por su labor publicitaria, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª)* núm. 374/2016, de 22 de julio (AC 2016\1430), cuantificando la indemnización en el 75 % de la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- La ausencia de pactos de exclusividad y la actuación promocional del empresario principal, así como la merma de las comisiones en la última época, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª)*, núm. 418/2010, de 13 de octubre (JUR 2011\23357), cuantificando la indemnización en el 75 % de la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- La escasa probabilidad de repetir pedidos por parte de muchos clientes, dado el objeto de la venta (enciclopedias, grandes colecciones musicales y culturales), en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª)*, núm. 245/2005, de 25 de mayo (AC 2005\208054), cuantificando la indemnización en el 75 % de la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- Las particularidades del sector del automóvil, en el que el cliente tiene en cuenta a la hora de tomar su decisión de adquirir el vehículo el pres-

tigio y esfuerzo publicitario de la marca, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4ª) núm. 142/2002, de 8 de marzo (JUR 2002\118754)*, estableciendo la indemnización en el 75 % de la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.

- La ausencia de pactos de limitación de la competencia del agente, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª) núm. 445/2012, de 30 de julio (AC 2012\1240)*, fijando la indemnización en el 75 % de la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- La permanencia de un solo cliente que aporta ventajas sustanciales y que no se aportaran nuevos clientes en los últimos años, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª), núm. 303/2008, de 8 de julio (JUR 2008\321263)*, para reducir la indemnización al 75 % del máximo legal.
- La ausencia de pactos de limitación de la competencia y la escasa duración del contrato, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª), núm. 53/2010, de 16 de febrero (AC 2010\514)*, para reducir la indemnización al 70 % del máximo legal.
- La ausencia de pactos de no competencia y exclusividad, el esfuerzo publicitario y de marketing por parte de la marca cuyos productos se comercializaron y su arraigo en el mercado de referencia, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª) núm. 168/2023, de 24 de marzo (JUR 2023\296153)*, para aplicar una reducción del 30 % con respecto a la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- La importante actividad publicitaria, promocional y de marketing por parte del empresario y la vida limitada de la cartera, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª) núm. 500\2018, de 8 de noviembre (JUR 2019\250)*, para aplicar una reducción del 30 % con respecto a la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- La ausencia de pacto de limitación de competencia y la corta duración contractual (2 años), en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª) núm. 2\2016, de 8 de enero (JUR 2016\30482)*, para reducir un 30 % la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- Las particularidades del sector, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19ª) núm. 265/2005, de 8 de junio (JUR 2005\176788)*, estableciendo la indemnización en el 60 % de la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- Las especialidades del sector del automóvil, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 2ª) núm. 360/2004, de 5 de noviembre*

(AC 2004\2385), cuantificando la indemnización en el 60 % de la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.

- La inexistencia de pactos de limitación de la competencia, la pérdida de clientela tras la extinción contractual y la actividad publicitaria del empresario, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 8ª)*, núm. 694/2002, de 5 de noviembre (JUR 2003\81126), fijando la indemnización en el 50 % de la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- La reducción de la facturación de los clientes captados por el agente, en las *Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª)* núm. 446\2009, de 21 de julio (JUR 2009\368274), y de la *Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª)*, núm. 128/2007, de 14 de mayo (AC 2007\1589), para aplicar una reducción del 50 % con respecto a la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- La ausencia de pacto de limitación de la competencia tras la extinción del contrato, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª)*, núm. 436/2007, de 5 de septiembre (JUR 2008\16111), para aplicar una reducción del 50 % con respecto a la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- La ausencia de pacto de limitación de la competencia tras la extinción del contrato, la importante inversión en publicidad del empresario principal y la pérdida de las remuneraciones por el consumo de los clientes, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 4ª)* núm. 326/2014, de 23 de julio (JUR 2014\265677) para imponer una reducción del 50 % con respecto a la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- La escasa duración contractual (17 meses), en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 11ª)* núm. 19/2016, de 27 de enero (JUR 2016\51072) para aplicar una reducción del 50 % con respecto a la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.
- El limitado provecho para el empresario de la clientela captada por el agente, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17ª)* de 16 de abril de 2003 (AC 2003\2029), para aplicar una reducción del 50 % con respecto al límite del art. 28.3 LCA.
- El escaso número de clientes aportados, la limitada incidencia de la clientela, el tiempo de duración del contrato —4 años— y la reducción en un treinta por ciento de las ventas de las últimas anualidades, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja (Sección 1ª)* núm. 4/2011, de 14 de

enero (AC 2011\290), para practicar una reducción del 30 % con respecto a la cantidad resultante de aplicar el límite del art. 28.3 LCA.

- La ausencia de pactos de limitación de la competencia, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª)*, núm. 298/2011, de 27 de mayo (AC 2011\1331), para reducir la indemnización a la cantidad de 67.626,53 euros, siendo el máximo legal 118.753,51 euros.
- El papel del empresario en la captación de clientes, creando canales de difusión masiva ajenos al agente informando a posibles clientes de sus productos y ofertas, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 6ª)* núm. 327/2014, de 11 de diciembre (JUR 2015\79437), para indemnizar al agente en el 40 % del importe resultante del máximo legal.
- El que el agente prestase servicios a otras empresas, aunque de menor trascendencia económica, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 3ª)*, núm. 211/2005, de 1 de febrero (JUR 2005\126148) para conceder como indemnización el 65,5 % del máximo legal.
- La incapacidad temporal del trabajador durante parte de la duración del contrato, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 2ª)* núm. 208/2019, de 4 de abril (AC 2019\1582), considerando acertado el criterio del juez de instancia fijando la indemnización en el 35 % del máximo legal.
- La vulneración de la prohibición de competencia por el agente, aunque no fuese considerada lo suficientemente grave y relevante para excluir toda la indemnización, así como la disminución de ventas en los últimos años no justificada por la situación del mercado ni por crisis económica, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3ª)* núm. 241\2016, de 20 de junio (JUR 2016\194298), para fijar la indemnización en una tercera parte del máximo.
- El grado de cumplimiento de objetivos, el tiempo de permanencia, la fuerza de la marca y la clientela real a fecha de extinción del contrato, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª)* núm. 267/2013, de 6 de septiembre (AC 2013\2338), para fijar la indemnización en la tercera parte del máximo.
- La notable reducción de la actividad y la escasa duración contractual en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 25ª)*, núm. 109/2010, de 22 de febrero (AC 2010\534), para fijar la indemnización en la tercera parte del máximo.

- La ausencia de exclusividad, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 3ª)*, núm. 236/2000, de 20 de noviembre (AC 2001\1469), para fijar la indemnización en la tercera parte del máximo.
- El que la indemnización coincidente con el límite máximo del art. 28.3 LCA debe quedar reservada para aquellos casos en que existen pactos de limitación de competencia, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª)* núm. 432 /2024, de 13 de junio de 2024 (JUR\2024\264174), para cuantificar la indemnización en un 25 % del máximo legal.
- El volumen de beneficios perdido tras la extinción contractual, la importancia de la labor del empresario en la captación de la clientela, el ser el único agente que comercializaba los productos la publicidad y difusión del producto llevada a cabo por la marca, la escasa duración de la relación contractual —dos años y la ausencia de pacto de prohibición de competencia tras la extinción contractual—, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 11ª)* núm. 460/2019, de 10 de julio (JUR 2019\1162), para conceder como indemnización el 25 % del máximo legal.
- La ausencia de datos sobre las concretas remuneraciones percibidas por el agente durante el período de duración del contrato, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 3ª)* núm. 295/2002, de 5 de noviembre (JUR 2003\18191), para indemnizar al agente en el 25 % del importe resultante del máximo legal.
- La breve duración contractual, el nulo o escaso consumo de la cartera aportada por la actora y el carácter dinámico del mercado, en el que la clientela es variable, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª)* núm. 252/2008, de 21 de mayo (AC 2008\1151), para indemnizar al agente en el 25 % del importe resultante del máximo legal.
- Las especialidades del sector del automóvil, la ausencia de pacto de exclusividad, el que el agente pudiera ofrecer a sus clientes vehículos de otras marcas y la labor publicitaria de la marca en la captación de clientela en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª*, núm. 56/2008, de 8 de febrero (JUR 2008\137137), para conceder como indemnización tres cuartas partes del máximo legal.
- El volumen de beneficios perdido tras la extinción contractual, la importancia de la labor del empresario en la captación de la clientela, el que los productos comercializados sean de marca renombrada, la escasa fidelización de la clientela en ese sector económico —telefonía móvil—, al existir un alto porcentaje de clientes que cambian a otra entidad competidora y la reducción de las retribuciones en los últimos 15 meses de contrato, aunque no se limite a la zona geográfica de actuación del agente, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª)* núm. 188/2016,

de 30 junio (AC 2016\1314), para conceder como indemnización el 20 % del máximo legal.

- La ausencia de cláusulas limitativas de la competencia, el descenso de comisiones por la crisis del sector del automóvil, la necesidad de conceder extras para facilitar las ventas y la existencia de notables gastos de explotación, con lo que las comisiones no eran netas, sino que el beneficio era muy inferior, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) núm. 329/2002, de 8 de octubre (JUR 2003\52581,)* para concretar la indemnización por clientela en la suma de 6.000 euros.
- El que la mayor parte de los clientes del agente fueron heredados de su predecesor, que la nueva zona adjudicada le fue retirada por falta de ventas y que la actuación del agente no produjo un aumento significativo de ventas, habiéndose reducido el negocio en los últimos años, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 2ª) núm. 136/2014, de 13 de junio (JUR 2014\198562)*, para fijar la indemnización por clientela en la suma de 6.000 euros.
- Las comisiones perdidas el último año y la tendencia a la baja de los pedidos de su clientela, así como la ausencia de pacto de limitación de la competencia, en la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª) núm. 153/2006, de 22 de mayo (AC 2006\967)* para rebajar la indemnización de 6.881 euros (máximo legal) a 5.000 euros.
- La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 18ª) núm. 387/2017, de 22 de noviembre (JUR 2018/28105)*, en un supuesto en el que se había pactado en el contrato que el agente percibiría una comisión adicional del 3 % de las ventas a cuenta de la posible indemnización por clientela, estimó que el agente no tenía derecho a percibir cantidad adicional alguna tras la extinción contractual valorando que el agente no había captado clientes de importancia ni gran número de clientes, con lo que la posibilidad de obtener el empresario un beneficio económico por tal clientela era muy limitada y no era previsible que excediera de las cantidades percibidas a cuenta de la indemnización por el 3 % adicional.

4. Especialidades en la agencia de vehículos

Dentro de los pronunciamientos judiciales sobre la indemnización por clientela, existe una doctrina específica para la agencia consistente en la venta de vehículos. En este sector los empresarios se oponen por sistema a dicha indemnización alegando que la actividad del agente no es susceptible de aprovechamiento sustancial por su parte, al no tratarse de una clientela estable y habitual, y en cuya labor de captación tiene un papel esencial la labor publicitaria y de marketing de la marca. Igualmente alegan, respecto de la venta de recambios, asistencia, reparación y

garantías, que también suele encomendarse al agente, que las retribuciones percibidas por tales conceptos no son subsumibles en el contrato de agencia, por lo que no se ha de tener en cuenta para su cálculo.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto en la *Sentencia de la Sala de lo Civil (Sección 1ª) núm. 102/2006, de 9 de febrero (RJ 2006\671)* declarando plenamente aplicable la indemnización del art. 28 LCA al negocio de la venta de vehículos nuevos. Argumenta que la distancia de los pedidos en el tiempo no impide la fidelización de los clientes⁴⁸. Por tanto, no cabe rechazar sin más el pago de indemnización por razón de la clientela en este sector económico, pues no impide cumplir con el requisito de que las relaciones comerciales creadas por el agente puedan perdurar en el futuro generando ventajas sustanciales e importantes para el empresario. Dicha clientela, además, continuará siéndolo previsiblemente en cuanto a las actividades de asistencia post-venta (revisiones, recambios, accesorios y asistencia en general) relacionada con los vehículos de la marca, pues lo habitual es que los compradores acudan a revisar y a repararlos en talleres y agencias oficiales, al estar especializadas y conocer mejor sus problemáticas técnicas.

En la misma línea, la *Sentencia de la Sala de lo Civil (Sección 1ª) núm. 358/2009, de 29 de mayo (RJ 2009\3050)* destaca que las características del mercado relevante —en ese caso, el sector de la compraventa de automóviles— no se incluyen entre los criterios fijados en el art. 28 para el cálculo del *quantum* de la indemnización.

No obstante, la escasa duración contractual de la agencia de vehículos (dos años no completos), unida a la falta de prueba clara del incremento de la clientela, se tuvo en cuenta para excluir la procedencia de la indemnización por clientela en la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 731/2007, de 26 de junio (RJ 2007\3449)*⁴⁹.

Por otro lado, si la acción de ventas se limita geográficamente a una zona concreta, la captación de clientes fuera de su zona se considera incumplimiento contractual por parte del agente (además de afectar a los derechos de otros agentes), privándole de su derecho a indemnización. Y también lo es el incumplimiento de los objetivos de financiación de vehículos por parte de los clientes compradores, según la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 583/2000, de 13 de junio (RJ 2000\5732)*.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) de 22 de febrero de 2002 (JUR 2002\116668)* destaca también las especialidades del sector del automóvil, en el que hay marcas muy conocidas en el mercado sobre las que los clientes tienen suficiente información, como el modelo a adquirir, y donde la

⁴⁸ En el mismo sentido, la *Sentencia de la Sala de lo Civil (Sección única) núm. 1071/2003, de 19 de noviembre (RJ 2003\8335)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 3ª) núm. 56/2008, de 8 de febrero (JUR 2008\137137)*.

⁴⁹ En el mismo sentido, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6ª) núm. 192/2024, de 29 de mayo de 2024 (JUR\2024\263452)*.

atracción comercial de la marca prestigiada opera de forma muy decisiva en la captación de clientes, que basan su decisión de adquirir el bien más en la publicidad del fabricante que en la actividad del agente o del concesionario.

En la misma línea se encuentra también la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida (Sección 2ª) núm. 85/2001, de 15 de febrero (AC 2001454)* que, además, descarta que proceda condenar al pago de indemnización alguna alegando que el empresario principal no podrá aprovechar la clientela, al haber dejado de ser concesionario de coches para esa marca.

Por su parte, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 2ª) núm. 108/2001, de 17 de abril (AC 2001/901)* rechazó conceder la indemnización al cuestionar que las relaciones comerciales creadas por el agente fueran susceptibles de seguir produciendo ventajas al empresario, dado que los clientes únicamente reciben suministros en muy largo plazo y no necesariamente de la misma marca.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7ª) núm. 76/2003, de 13 de febrero (AC 2003\833)* también relativiza el papel del agente en este sector en base a la fidelidad de los clientes a la marca y al carácter de bien de larga duración de los vehículos. Pese a tales afirmaciones, dicha resolución concedió una indemnización por clientela al agente teniendo en cuenta su antigüedad de más de 28 años en la plaza, sus buenos resultados en las encuestas de calidad y trato al cliente, su volumen de ventas y el de mantenimientos y revisiones técnicas adquiriendo piezas de recambio del empresario.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª) núm. 270/1998, de 15 de mayo (AC 1998\5602)*, respecto del requisito del aprovechamiento futuro por el empresario de la clientela captada por el agente, ha resaltado las peculiaridades de este sector, que debe ser tenida en cuenta a la hora de cuantificar la indemnización: «si la clientela la forman la suma de clientes fieles a una determinada marca que compran los productos de la misma de forma reiterada y tradicional, es indudable que en su captación influye de manera decisiva la marca o el fabricante ya que el modelo de vehículo es un hecho determinante para su adquisición. Si a ello se añade la circunstancia de ser el automóvil un bien de larga duración y precio elevado para cualquier economía, así como la intensa publicidad que los fabricantes hacen de cada modelo que lanzan al mercado, forzoso es concluir que la creación de clientela por las redes de distribución y concretamente por las denominadas secundarias (agencias de las concesionarias) es muy reducida, pues ni los pedidos son repetitivos, ni normalmente los mismos, de darse, se deben a una fidelidad al agente sino fundamentalmente a la propia marca o imagen creada por la misma en la publicidad». Pese a ello, destaca que la clientela captada por el agente continuará produciendo ventajas al empresario en cuanto a la venta de piezas de recambio y talleres de reparación, dado que los clientes de la marca acuden habitualmente a reparar y efectuar las revisiones de sus vehículos a los talleres y agencias oficiales de la marca, dada su especialización.

En el mismo sentido, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4ª) núm. 142/2002, de 8 de marzo (JUR 2002\118754)* redujo un 25 % la cantidad resultante del máximo legal del art. 28.3 LCA por la especial significación de la marca y de la promoción de esta en la creación de una clientela, que relativiza la importancia de la actividad de los agentes en el sector del automóvil.

Mayor fue la reducción (40 %) aplicada por la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 2ª) núm. 360/2004, de 5 de noviembre (AC 2004\2385)* al considerar las especialidades de este sector: «tratándose el objeto de la relación de venta de automóviles de una marca muy conocida en el mercado —Citroën—, de la cual los clientes cuentan con suficientes noticias e información, así como del tipo y modelo que tienen intención de adquirir, las mismas actúan por sí como reclamo decidido para la compra del vehículo y sirven de atracción comercial de la marca prestigiada, que opera de forma muy decisiva en la captación de usuarios, ya que estos suelen atender más a la publicidad general del fabricante que a la limitada que pueda desplegar el concesionario o agente, que en todo caso se aprovecha de aquella, pues no suele intervenir en la confección de catálogos generales e impresos publicitarios y su actividad se concreta en la mayoría de los casos a su distribución y venta y anuncio mediante rótulos en las fachadas de sus establecimientos y correspondencia comercial (STS de 12 de junio 1999 [RJ 1999, 4292], SAP de Asturias de 15 mayo 1998 [AC 1998, 949]). Ello no es óbice para conocer la intervención del agente, que a través de un servicio de post-venta y reparación adecuada e incluso notable, también colabora a la creación, mantenimiento e incremento de la clientela, pero ponderando su actividad en tanto no es ni con mucho exclusiva en la creación de clientela automovilística».

A favor de moderar la indemnización se pronunció también la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª) núm. 270/1998, de 15 de mayo (AC 1998/49)* que, además del papel del fabricante en la captación de clientes, tuvo en cuenta que el automóvil es un bien de larga duración y precio elevado para cualquier economía.

Ninguna reducción en la indemnización por clientela aplicó, en cambio, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 2ª) núm. 216/2002, de 13 de diciembre (JUR 2003/35627)*, pese a reconocer las peculiaridades de este sector, al tener en cuenta el aprovechamiento de la clientela generada por el agente en cuando a garantía y servicios postventa de mantenimiento y taller oficial, incluyendo, además, a efectos de las retribuciones para el cálculo de la indemnización, no solo las comisiones por venta, sino también los ingresos del agente por taller y mantenimiento post-venta. Tampoco aplicó reducción alguna la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª) núm. 713/1999, de 27 de diciembre (AC 1999/255)*.

En definitiva, pese a que la indemnización por clientela no queda excluida en el caso de la agencia de venta de vehículos, en este sector es más frecuente encontrar pronunciamientos judiciales que la excluyen o que, aun reconociéndola, moderan la indemnización por debajo del límite legal del art. 28.3 LCA.

Parece justificado que las indemnizaciones a conceder al agente en el sector del automóvil sean considerablemente inferiores al máximo legal, teniendo en cuenta,

entre otros criterios, que el esfuerzo publicitario de la marca tiene un papel fundamental a la hora de atraer a la clientela y que los vehículos son bienes de larga duración, lo que dificulta que la actividad del agente pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario.

III. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

1. Régimen legal

El art. 29 LCA otorga al agente la posibilidad de reclamar al empresario que denuncie unilateralmente el contrato de agencia de duración indefinida la indemnización de cuantos daños y perjuicios le haya ocasionado, en su caso, la extinción anticipada del contrato, cuando tal terminación no haya permitido la amortización de los gastos⁵⁰ en que el agente, instruido por empresario, haya incurrido para la ejecución del contrato. Tal indemnización es, además, independiente de la que le corresponda por clientela.

El precepto se basa en el art. 17 de la Directiva, que reconoce al agente derecho a indemnización o reparación del perjuicio tras la extinción del contrato y, en especial, cuando se haya producido en unas condiciones «que no hayan permitido al agente comercial amortizar los gastos que hubiere realizado para la ejecución del contrato aconsejado por el empresario». Dicha indemnización queda excluida en los mismos supuestos que previstos para la indemnización por clientela (art. 18 de la Directiva).

Se ha destacado que el art. 29 LCA constituye una norma polémica, fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque España ha sido el único país que ha optado por un criterio acumulativo a la hora de regular las indemnizaciones derivadas del contrato de agencia (en vez de alternativo como prevé la Directiva Europea) y, en segundo lugar, porque esta indemnización no sustituye a la general de daños y perjuicios del artículo 1.101 del Código Civil, sino que también es compatible con ella⁵¹.

La indemnización resulta aplicable cuando el agente comercial haya ejercido su actividad en un Estado miembro, aun cuando el empresario se halle establecido en un país tercero y el contrato se rija por la Ley de ese tercer país en virtud de una de sus cláusulas, según la *Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) de 9 noviembre de 2000 (TJCE 2000\270)*⁵².

La operativa de la indemnización *ex art. 29 LCA* precisa: (i) un contrato de agencia de duración indefinida, descartando así los de duración determinada; (ii) la extinción contractual; (iii) la existencia de gastos no amortizados, (iv) que tales

⁵⁰ ALONSO ESPINOSA, F. J., *Derecho Mercantil de Contratos*, Thomson Reuters, Navarra, 2011, p. 86, apunta que este aspecto se habrá de concretar mediante la aplicación de las normas contables que correspondan y, en especial, el Plan General de Contabilidad.

⁵¹ ALONSO SOTO, R., «Contenido del contrato de agencias», *Estudios y Comentarios Legislativos Civitas* (BIB\2007\3417).

⁵² Caso Ingmar GB Ltd contra Eaton Leonard Technologies Inc.

gastos sean necesarios para la ejecución del contrato, y (v) que hayan sido realizados por el agente instruido por el empresario.

No obstante, los tribunales también reconocen la posibilidad de indemnizar al agente otros gastos que, si bien no tienen encaje en el art. 29 LCA, sí tendrían naturaleza resarcible según las normas de los arts. 1101 y concordantes del Código Civil.

2. Imposibilidad de pacto en perjuicio del agente

Sin perjuicio del carácter imperativo de la regulación legal que recoge el art. 3 LCA, el art. 19 de la Directiva impide pactar antes del vencimiento del contrato una indemnización de daños y perjuicios a favor del agente distinta de la legal en perjuicio de este.

Por tanto, al igual que en la indemnización por clientela, únicamente son admisibles: (i) los pactos que recojan una regulación más favorable para el agente; (ii) los pactos que, aun siendo más desfavorables para el agente, se celebren tras la extinción del contrato.

3. La interpretación de la indemnización por daños y perjuicios del art. 29 LCA por parte de los tribunales

Los tribunales han ido estableciendo criterios interpretativos sobre la indemnización del art. 29 LCA, si bien las sentencias sobre este particular son menos numerosas que las relativas a la indemnización por clientela.

Las *Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 371/2009, de 2 de junio (RJ 2009\3366) y núm. 736/2007, de 27 de junio (RJ 2007\4675)* consideran erróneo basar la indemnización prevista en el art. 29 LCA en el art. 1.101 CC, que exige como presupuesto normativo que se haya incurrido en dolo o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, puesto que el art. 29 LCA no precisa que en la resolución unilateral del vínculo contractual haya mala fe o que constituya una conducta abusiva, sino que los presupuestos para que opere son los siguientes⁵³: 1) duración indefinida del contrato de agencia; 2) denuncia unilateral por el empresario, salvo que sea por causa del incumplimiento de las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente; 3) existencia de gastos de inversión o adecuación pendientes de amortización por el agente, que deben ser acreditados por el demandante; 4) que los gastos se hayan realizado en virtud de instrucciones del empresario, entendiendo que lo han sido, no solo cuando existan órdenes expresas en ese sentido, sino también cuando la inversión fue necesaria para acometer convenientemente el encargo, y 5) que la extinción anticipada no permita la amortización.

⁵³ En el mismo sentido, la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 1296/2007, de 11 de diciembre (RJ 2007\8917)*.

Respecto del requisito de la duración indefinida del contrato, en un supuesto en el que el contrato de agencia se concertó inicialmente con una duración de ocho meses, sin posibilidad de prórroga, transformado después en indefinido, el TS rechazó la procedencia de la indemnización por inversiones realizadas antes de su transformación en indefinido en base a que no resultaba acreditado que se hubieran realizado exclusivamente en atención a las expectativas creadas por el contrato temporal, según la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 1054/1998, de 17 de noviembre (RJ 1998\8811)*.

La *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 356/2016, de 30 de mayo (RJ 2016) 2293* ha señalado que «doctrina y jurisprudencia son concordes en que las inversiones amortizables son las relativas al inmovilizado y los gastos que deban distribuirse entre varios ejercicios. Se trata de una indemnización del daño emergente, no del lucro cesante (que tendría su amparo, no en este precepto, sino en los arts. 1101 y 1106 C.C.), según la sentencia 346/2006, de 20 de mayo (RJ 2009, 3184) y las que en ella se citan; y solo de las denominadas «inversiones específicas», es decir, las que pierden su valor a la terminación del contrato».

La *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección única) núm. 633/2013, de 29 de octubre (RJ 2013\ 7033)* ha declarado que únicamente «son indemnizables los gastos o inversiones causados para poner en marcha o adecuar su empresa, conforme a las instrucciones expresas o implícitas del empresario, que no se hubieran amortizado al extinguirse la relación. Por ello, cuando las inversiones pueden ser destinadas al servicio de otros empresarios o usadas en beneficio propio decae la razón de ser de la indemnización por los llamados “gastos de confianza”». Además, para que proceda la indemnización, se ha de tratar de gastos de inversión o adecuación pendientes de amortización por el agente que se hayan realizado en virtud de instrucciones del cliente, siempre que la resolución no permita su amortización. En particular, dicha Sentencia descarta que sean indemnizables la nave y terrenos anexos, al suponer una inversión que puede ser destinada a cualquier otra actividad, venta o arriendo.

La *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección única) núm. 1071/2003, de 19 de noviembre (RJ 2003\8335)* declaró que «se trata de daños y perjuicios cuya existencia y cuantía depende de su acreditación en cada caso, y se refiere a los gastos realizados a instancia del empresario, aunque estos deben entenderse no solo cuando existan órdenes expresas en ese sentido, sino también si la inversión fuera para desarrollar convenientemente el encargo conferido» y rechazó que tuvieran encaje en el art. 29 LCA el importe de los servicios de teléfono, agua y electricidad, las rentas mensuales del local, el coste de diverso mobiliario o pagos por adquisición de flores, al no estar acreditada su relación con el contrato de agencia en algunos casos y, en otros, por haber quedado compensados tales gastos durante la vigencia del contrato.

Por su parte, la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección única) núm. 572009, de 13 de febrero (RJ 2009\1490)* consideró indemnizables los

gastos en material de oficina inservible adquirido para el contrato de agencia, pero no así las indemnizaciones satisfechas a empleados por despido, aunque estas sí lo eran con arreglo al art. 1101 del Código Civil.

El lucro cesante del agente por la existencia de un pacto de limitación de la competencia no puede ser englobado dentro del derecho a la indemnización del art. 29 LCA, aclara la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 11ª) núm. 682/2004, de 4 de octubre (AC 2004\1963)*.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) núm. 335/2017, de 2 octubre (JUR 2017\275330)* tampoco consideró indemnizable el gasto realizado por el agente para la adquisición de una caja fuerte de seguridad, al ser de cargo del agente los gastos de infraestructura para el desempeño de su actividad, realizarse la inversión en el último año de vigencia del contrato y quedar la caja en propiedad del agente para cualesquiera otros usos y destinos tras la conclusión del contrato.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 3ª) núm. 324/2016, de 30 de diciembre (JUR 2017\64593)* rechazó incluir en la indemnización del art. 29 LCA los gastos por compra de impresora, ordenador, pantalla de ordenador y *software* diseñado para la gestión del agente, así como el mobiliario de oficina y un vehículo, pues todas ellas podían continuar siendo empleadas por el agente comercial multicartera tras la extinción del contrato e, incluso, para su uso personal, no cumpliéndose el requisito de que no fuese posible la amortización de tales gastos tras la extinción contractual.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 6ª) núm. 327/2014, de 11 de diciembre (JUR 2015\79437)* rechazó indemnizar por el coste del programa informático y de infraestructura que tuvo que abonar el agente para incorporarse al proyecto del empresario y que quedó inservible tras el desistimiento unilateral del empresario porque el contrato duró el triple del período inicialmente previsto y, teniendo en cuenta los usos y períodos de amortización normales del sector, lo más probable es que ya se encontrasen completamente amortizados esos elementos.

Por el contrario, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7ª) núm. 76/2003, de 13 de febrero (AC 2003\833)* concedió indemnización por extinción sorpresiva del contrato de agencia comprensiva de la maquinaria y utillaje no amortizado, obra civil y pintura para dejar el establecimiento en condiciones normales de uso después de eliminar los símbolos, signos y marcas del empresario y las piezas de repuesto no amortizadas, al desaparecer el volumen de negocio del agente tras dicha extinción contractual.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 3ª) núm. 331/2006, de 17 de julio (AC 2006\1532)* consideró incluibles dentro de la indemnización del art. 29 LCA los gastos en que se ha incurrido para adaptarse a las formas y pautas exigidas al establecimiento del agente por parte de la marca Seat, en el caso de agencia del sector automovilístico, dado que, tras la extinción

contractual por denuncia unilateral del empresario, el agente deberá modificar nuevamente la configuración de su local.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia (Sección Única) núm. 121/2001, de 24 de abril (AC 2001\930)* calificó como indemnizables los gastos en las tarjetas y demás documentación encargada con el anagrama de la empresa, letreros publicitarios pintados en vehículos y el rótulo del establecimiento que, por la extinción sorpresiva del empresario, resultaron inservibles al agente, pero no así la cámara frigorífica adquirida 6 años antes de la extinción del contrato, por el período de amortización transcurrido y por la posibilidad de utilizarla para otros fines futuros.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª) núm. 325/2015, de 9 de noviembre (AC 2015\1730)* concedió como indemnización el coste de la extinción de los trabajadores contratados tras el contrato de agencia que hubo que despedir a su finalización, si bien tales gastos deberían, en realidad, indemnizarse al amparo del Código Civil, no del art. 29 LCA, según jurisprudencia del TS que se cita en el siguiente apartado.

La concesión de indemnización en base al art. 29 LCA debe limitarse a los concretos daños y perjuicios que resulten acreditados, siempre y cuando se trate de gastos realizados para la ejecución del contrato que no puedan ser amortizados tras la extinción del contrato, sin que quepa extender la indemnización a cualquier otro perjuicio que la finalización contractual ocasione al agente.

4. La posible indemnización de otros daños y perjuicios que la extinción contractual ocasione al agente con arreglo al Código Civil

Los tribunales también conceden al agente la posibilidad de reclamar la indemnización de otros daños y perjuicios que la extinción contractual les haya ocasionado, sin concurrir los presupuestos del art. 29 LCA.

Por lo que se refiere al daño emergente, la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección única) núm. 633/2013, de 29 de octubre (RJ 2013\7033)* declaró la procedencia de la indemnización por el coste que supuso resolver los contratos laborales al agente, no con base en el art. 29 LCA, sino con fundamento en el régimen general del art. 1.101 del Código Civil. En términos similares, la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección única) núm. 572009, de 13 de febrero (RJ 2009\1490)* consideró que no tenían encaje en el art. 29 LCA las indemnizaciones satisfechas a empleados por despido, pero sí eran indemnizables con arreglo al art. 1101 del Código Civil. Sin embargo, siendo el agente un empresario independiente, no parece lógico que la otra parte del contrato deba soportar los costes laborales a los que deba hacer frente su agente.

En cambio, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 3ª) núm. 156/2017, de 22 mayo (JUR 2017\175130)* no estimó indemnizables los gastos

relativos a la indemnización por despido de los trabajadores del agente en un supuesto de contrato de agencia de duración determinada, alegando que el agente conocía de antemano la duración contractual, por lo que pudo prever con antelación sus consecuencias, ni el lucro cesante por pérdida de ganancias. Sí consideró, en cambio, indemnizables, los gastos por depósito de mercancías del empresario tras la extinción contractual.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 1ª) núm. 185/2013, de 12 abril (AC 2013\1438)*, con buen criterio, rechazó la pretensión de indemnización de daños y perjuicios por la extinción anticipada del contrato de arrendamiento de oficinas, al no constar que fuese exigido por el empresario ni estar acreditada la exclusividad de la relación contractual.

En cuanto al lucro cesante, ante un supuesto en que el empresario (aseguradora) había decidido unilateralmente no prorrogar las pólizas de la cartera de clientes del agente, pese a que gozaban de modificaciones por no siniestralidad, pero, tras la extinción de tales pólizas, volvió a celebrar con algunos de tales clientes una nueva, induciéndoles a depender de otro agente distinto, la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 778/2005, de 7 de octubre (RJ 2005\7700)* condenó al empresario a indemnizar al antiguo agente con el pago de las comisiones que le hubieran correspondido respecto de los clientes con los que suscribió una nueva póliza, en base al deber de buena fe que impone al empresario el art. 10.1 LCA y a los arts. 1101 y 1106 del Código Civil.

Por su parte, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7ª) núm. 604/2002, de 31 de octubre (AC 2003/111)* rechazó la procedencia de una indemnización por lucro cesante, tras conceder la indemnización por clientela en la cuantía correspondiente al máximo legal, al no estar legalmente prevista dicha compensación reclamada. En términos similares se pronunciaron la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3ª) núm. 511/1999, de 29 de diciembre* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª) núm. 713/1999, de 27 de diciembre (AC 1999/255)*, al considerar que no cabe reclamar indemnización por pérdida de comisiones, pues tal concepto ya está retribuido mediante la indemnización por clientela. Y en el mismo sentido, también se encuentra la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª) núm. 183/2016, de 11 de abril (AC 2016\1198)*. Si la concede, en cambio, además de la indemnización por clientela, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 2ª) núm. 4/2018, de 10 de enero (JUR 2018\64868)*, en base al art. 1101 CC y ante el incumplimiento contractual durante la vigencia del contrato de agencia por parte del empresario, considerando nula la cláusula de limitación de responsabilidad a la suma de las comisiones percibidas durante los seis meses precedentes al incumplimiento.

IV. INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PREAVISO

Aunque no está expresamente prevista esta indemnización en la LCA, la necesidad de preavisar viene impuesta, además de por el art. 25 LCA, por las exigencias del prin-

cipio de buena fe y deber de lealtad que el art. 10.1 LCA impone al empresario, cuyo incumplimiento puede ser considerado como ejercicio abusivo del derecho o contrario a las exigencias de la buena fe. No obstante, las *Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 26/2019, de 17 de enero (RJ 2019\74), n° 317/2017, de 19 de mayo (RJ 2017\2228), n° 569/2013, de 8 de octubre (RJ 2013\ 8002), y n° 480/2012, de 18 de julio (RJ 2012\8363)* dejan claro que la resolución unilateral sin preaviso del contrato de agencia no produce necesariamente un daño indemnizable y, en su caso, que este no tiene por qué coincidir con el promedio de remuneraciones percibidas por el agente durante el período de tiempo cubierto por el preaviso. De proceder la indemnización, el criterio del beneficio medio mensual de los últimos cinco años del contrato de agencia (o de la duración del contrato, de ser inferior) multiplicado por los meses omitidos de preaviso constituye un método razonable, pero no único, de calcular la indemnización.

Por su parte la *Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 977/2005, de 19 de diciembre (RJ 2006\295)* ha declarado la compatibilidad de la indemnización por falta de preaviso con la indemnización por clientela o por inversiones no amortizadas que el agente haya realizado para la ejecución del contrato y recuerda que el plazo de preaviso no necesita pactarse en el contrato de duración indefinida, pues viene impuesto con carácter imperativo en el art. 25 LCA.

Sobre la naturaleza de esta indemnización, las *Sentencias de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª) núm. 2\2016, de 8 de enero (JUR 2016\30482)* y la de la *Sección 1ª* de la misma Audiencia núm. 242/2012, de 8 de mayo (AC 2012\1009) destacan que la cobertura legal de la indemnización de perjuicios derivada del citado incumplimiento de la obligación legal de preaviso se localizaría en el art. 1.101 Código Civil, de modo que el incumplimiento del plazo de preaviso legalmente establecido ocasiona un daño que ha de ser indemnizado, como toda obligación incumplida (artículos 50 del Código de Comercio y 1101 y siguientes del Código Civil) y esta indemnización, que se ve referida en la mayor parte de los casos al lucro cesante, ha de alcanzar al importe de las comisiones que el agente habría previsiblemente obtenido si la empresa hubiera adecuado su actuación a los parámetros legales que rigen la resolución contractual.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª), núm. 303/2008, de 8 de julio (JUR 2008\321263)* recuerda que el empresario puede resolver el contrato sin causa, pero el preaviso es obligatorio, siendo ineficaz el pacto en contrario, aunque pueden pactarse preavisos superiores a los legales.

Si el empresario considera que existe justa causa para dar por finalizado el contrato sin preaviso deberá precisar la causa de la extinción (incumplimiento contractual o declaración de concurso), pero «no es necesario que se detallen con absoluta precisión las causas concretas y específicas por las que se adopta la resolución, a modo de carta de despido laboral o pliego de cargos sancionador», aunque la buena fe contractual aconseja concretar en qué consistió el incumplimiento que se imputa al agente, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo (Sección 1ª) núm. 362/2016, de 16 de septiembre (AC 2016\1993)*.

Por otro lado, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de mayo de 2005* reconoció indemnización por falta de preaviso al agente que había solicitado la resolución del contrato por incumplimiento de sus obligaciones por parte del empresario⁵⁴.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja núm. 401/2002, de 9 de octubre (AC 2002\2230)* aclara que, si bien no está legalmente prevista de forma específica esta indemnización, su aplicación resulta de las normas generales en materia de obligaciones (art. 1101 CC), sin que su concesión esté condicionada a que concurran los requisitos del art. 29 LCA sobre la necesidad de amortizar inversiones pendientes, ni viceversa. También destaca la independencia de ambos conceptos indemnizatorios la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª), de 13 de marzo de 2002 (AC 2002\986)*.

Para un contrato de agencia de seguros la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), núm. 172/2016, de 20 de julio (AC 2016\1925)*, no consideró que debiera declararse la nulidad de la cláusula contractual que reducía el plazo legal de preaviso al agente a quince días.

Por otro lado, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) núm. 279/2009, de 15 de mayo (AC 2009\1086)* se ha ocupado de las consecuencias de la falta de preaviso por parte del agente, señalando que la resolución contractual intempestiva e inesperada por parte del agente también supone un abuso de derecho, que puede dar lugar a que el agente deba indemnizar al empresario, pero no priva al agente de su derecho a la indemnización por clientela.

Los pronunciamientos de las Audiencias Provinciales sobre esta indemnización se pueden clasificar en tres grupos: los que conceden una indemnización equivalente a la media mensual de las retribuciones percibidas multiplicada por los meses de preaviso omitidos, los que conceden indemnización en menor importe y los que rechazan la procedencia de la indemnización.

Parece razonable indemnizar al agente por el lucro cesante que el incumplimiento legal del deber de preaviso le ha ocasionado. Asimismo, es conveniente establecer un criterio objetivo para su cálculo, como la media mensual de retribuciones multiplicada por los meses de preaviso omitidos. No obstante, como quiera que se trata de indemnizar un lucro cesante, sería preferible calcular la media mensual sobre las retribuciones percibidas en el último año de contrato —o durante toda su duración, de ser inferior—, y no sobre las de los últimos cinco años, que previsiblemente será superior. Téngase en cuenta que en muchos casos la decisión de resolver el contrato por parte del empresario vendrá motivada por un descenso en las ventas y, por tanto, de las remuneraciones del agente, por lo que el lucro cesante debe intentar ajustarse a las remuneraciones que habría percibido el agente de haber cumplido el empresario el deber de preaviso.

⁵⁴ GADEA SOLER, E. y SACRISTÁN BERGIA, F., *El contrato de Agencia. La Ley 12/1992 en la jurisprudencia*, Ed. La Ley, Madrid, 2010, pp. 142 y ss.

1. Indemnización equivalente a la media mensual de las retribuciones percibidas en los últimos cinco años (o período de duración contractual, si es inferior) multiplicada sobre los meses de preaviso omitidos

La gran mayoría de resoluciones judiciales optan por fijar la indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del plazo de preaviso en la denuncia unilateral del contrato por parte del empresario en la cantidad resultante de multiplicar la retribución media mensual obtenida por el agente durante los últimos cinco años del contrato —o durante toda su duración, de ser inferior— por el número de meses de preaviso omitidos⁵⁵.

En este grupo de sentencias también se encuentra la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 79/2020, de 22 de mayo (AC 2021\916)*, que concedió como indemnización la media mensual de retribución sobre los meses que duró la relación contractual, si bien aplicando una reducción, ya que dicho cálculo supondría concederle más cantidad que la que solicitaba en la demanda, por lo que acabó fijando la indemnización en la suma reclamada por el demandante por tal concepto. La reducción aplicada se debió únicamente a que no cabe conceder en sentencia más de lo pedido en la demanda, por lo que, pese a rebajar la indemnización, se debe incluir dentro del sector mayoritario.

⁵⁵ En este sentido, se encuentran: *Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 6ª) núm. 186/2024, de 21 de junio (JUR\2024\300524)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) núm. 601/2019, de 16 de diciembre (AC 2020\513)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 8ª) núm. 404/2019, de 18 de julio (AC 2019\1680)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) núm. 432/2024, de 13 de junio de 2024 (JUR\2024\264174)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 113/2018, de 6 de marzo (AC 2018\1160)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª) núm. 208/2015, de 18 de mayo (JUR 2015\157486)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) núm. 268/2008, de 24 de abril (AC 2008\1064)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) núm. 374/2016, de 22 de julio (AC 2016\1430)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6ª) núm. 290/2024, de 19 de julio (JUR\2024\409224)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 2ª) núm. 10/2024, de 9 de enero de 2024 (JUR\2024\119503)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 5ª) núm. 214/2016, de 30 de mayo (AC 2016\2089)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª) núm. 881/2024, de 20 de junio de 2024 (JUR\2024\303232)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 3ª) núm. 109/2013, de 6 de marzo (AC 2014\866)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 3ª) núm. 168/2013, de 18 de abril (AC 2014\739)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 5ª) de 17 de diciembre de 1997 (AC 1997\2397)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 2ª) de 18 de enero de 2000 (AC 2000\23)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) núm. 424/2012, de 28 de noviembre (AC 2013\810)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª) núm. 295/2015, de 12 de noviembre (JUR 2016\131065)*, *Sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) núm. 335/2017, de 2 de octubre (JUR 2017\275330) y núm. 32/2010, de 1 de febrero (JUR 2010\112810)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) núm. 322/2017, de 6 de julio (JUR 2017\244856)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4ª) núm. 342/2010, de 18 de mayo (AC 2010\1414)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 2ª) núm. 256/2006, de 9 de mayo (AC 2006\855)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 2ª) núm. 351/2010, de 4 de junio (JUR 2010\37714)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) núm. 344/2016, de 14 de junio (JUR 2016\186432)*, *Sentencias de la Audiencia Provincial de*

2. Sentencias que conceden otros importes de indemnización

Por el contrario, otras resoluciones, apartándose del criterio mayoritario, han concedido indemnizaciones de menor importe.

Así, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19ª)*, núm. 41/2004, de 23 de enero (JUR 2004\53182) rebajó un 10 % la indemnización resultante del cálculo de la retribución media —al igual que la de clientela— dado que la mayoría de los clientes habían sido captados, no por la agente, sino por su padre fallecido, en cuya posición contractual se subrogó.

Y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 3ª)* núm. 429/2010, de 23 de noviembre (AC 2010\2211) la redujo en un 25 % falta de aportación rigurosa de documentación contable.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 3ª)* núm. 324/2016, de 30 de diciembre (JUR 2017\64593) consideró únicamente indemnizable la facturación mensual media calculada para un período de 20 días (no de los meses cuyo preaviso fue omitido), pues entendió que este fue el tiempo que el agente precisó desde la extinción del contrato hasta que reorientó su actividad comercial con otro empresario.

La *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª)* núm. 168/2023, de 24 marzo (JUR 2023\296153) confirmó la sentencia de instancia, que fijó una indemnización para ese caso concreto teniendo en cuenta el ciclo comercial y de venta de productos correspondiente a los seis meses posteriores al fin de la relación contractual —plazo de preaviso omitido— y sin tener en cuenta en dicho cálculo las comisiones generadas por clientes cedidos temporalmente que se encontraban fuera del ámbito territorial de actuación del agente.

3. No conceden indemnización por incumplimiento del deber de preaviso en plazo

También se encuentran algunas sentencias, mucho menos numerosas, en las que los tribunales rechazan conceder indemnización alguna por este incumpli-

Asturias (Sección 7ª) núm. 675/2009, de 4 de diciembre (AC 2010\78) y núm. 135/2009, de 6 de marzo (JUR 2009\275288), *Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 3ª)* núm. 211/2005, de 1 de febrero (JUR 2005\126148), *Sentencia de la Audiencia Provincial de León (Sección 3ª)* núm. 192/2004, de 4 de junio (AC 2004\903), *Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7ª)* núm. 604/2002, de 31 de octubre (AC 2003\111), *Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja* núm. 401/2002, de 9 de octubre (AC 2002\2230), *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª)*, núm. 303/2008, de 8 de julio (JUR 2008\321263), *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª)* núm. 197/2007, de 30 de marzo (AC 2007\957), *Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 2ª)* núm. 370/2015, de 23 de diciembre (JUR 2016\31693), *Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3ª)* núm. 109/2015, de 15 de abril (JUR 2015\126242) y *Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª)* núm. 2\2016, de 8 de enero (JUR 2016\30482).

miento del empresario. Así, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) núm. 33/2018, de 29 de enero (AC 2018\161)* sostiene que el incumplimiento de la obligación legal de preaviso —seis meses en dicho supuesto— no determina *in re ipsa* la producción de un daño, sino que deviene imprescindible acreditar la existencia de los perjuicios, así como que los mismos son consecuencia de ese concreto incumplimiento, perjuicio que descartó, además de por falta de prueba, porque el actor inició su actividad comercial para otra empresa del sector a mediados del mes siguiente a la fecha de denuncia unilateral.

En la misma línea, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 11ª) núm. 19/2016, de 27 de enero (JUR 2016\51072)* rechazó la indemnización por falta de preaviso al no haber acreditado el demandante el daño que alegaba, sin que la indemnización por falta de preaviso tenga carácter automático⁵⁶.

V. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA RECLAMACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR EL AGENTE

Si bien el art. 4 LCA remite, con carácter general, para la prescripción de las acciones derivadas del contrato de agencia a las reglas establecidas en el Código de Comercio, el art. 31 LCA establece un plazo de prescripción especial para interponer la acción de indemnización por clientela o por daños y perjuicios, que es de un año a contar desde la extinción del contrato⁵⁷. Se trata de un plazo civil, que se cuenta, por tanto, de fecha a fecha⁵⁸.

La demanda deberá interponerse ante los tribunales del domicilio del agente, al existir una norma de competencia territorial para conocer de las acciones derivadas del contrato de agencia (Disposición adicional segunda LCA), cuyo pacto en contrario se sanciona con la nulidad⁵⁹. Resulta criticable que dicho fuero legal imperativo no haya sido incorporado a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el abogado del agente no se toma la molestia de leer la Disposición adicional segunda

⁵⁶ Al igual que la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 4ª) núm. 622/2010, de 9 de diciembre (AC 2011\726)*, *Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª) núm. 217/2024, de 8 de marzo de 2024 (JUR\2024\232208)* y la de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª) núm. 229/2003, de 12 de mayo (JUR 2003\232564).

⁵⁷ La interposición de demanda de conciliación interrumpe el plazo del art. 31 LCA según recuerda, citando doctrina general del TS, la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11ª) núm. 450/2006, de 15 de diciembre (AC 2007\524)*, como también la reclamación extrajudicial por carta, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 3ª) núm. 236/2003, de 6 de octubre (AC 2003\2107)* y la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 2ª) núm. 200/2001, de 17 de abril (AC 2001\1582)*. Por el contrario, la interposición de demanda inadmitida por falta de competencia objetiva carece de eficacia interruptora de la prescripción, al no llegar a conocimiento del deudor, al que no le fue notificada la demanda, según la *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª) núm. 527/2017, de 30 de octubre (JUR 2017\292738)*.

⁵⁸ *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª) núm. 17/2004, de 27 de enero (JUR 2004\53967)*.

⁵⁹ *Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 755/2000, de 12 de julio (RJ 2000\6018) y de 26 de diciembre de 1996 (RJ 1996\9508)*.

LCA, limitándose a comprobar la falta de mención al contrato de agencia en el listado del art. 52 LEC, interpondrá la demanda ante el tribunal del domicilio del demandado que, de ser distinto que el del domicilio del demandante, dará lugar a la apreciación de la falta de competencia territorial. La falta de competencia puede ser declarada de oficio por el LAJ, que, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, en su caso, pasará las actuaciones al juez para que mediante auto declare la falta de competencia territorial y remita las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente (art. 58 LEC). O a instancia de la parte demandada, mediante la interposición de la correspondiente declinatoria (art. 59 LEC). Este problema, que conlleva un desperdicio de recursos de la Administración de justicia, se evitaría fácilmente incluyendo el fuero en la LEC.

VI. CONCLUSIONES

La extinción del contrato de agencia permite en muchos casos al agente reclamar indemnizaciones al empresario.

Tanto si se ha celebrado el contrato por tiempo determinado como si lo ha sido con carácter indefinido, el agente podrá solicitar la indemnización por clientela, así como una indemnización de daños y perjuicios en base al régimen general de los arts. 1.101 y 1.106 del Código Civil.

La indemnización por clientela tiene por objeto ofrecer al agente una compensación económica por los nuevos clientes que ha aportado al empresario o por el aumento de operaciones logrado con la clientela anterior. Se basa en que el trabajo generado por el agente durante la vigencia del contrato continuará produciendo ventajas para el empresario tras la extinción contractual, no así para el agente. Tal indemnización, no susceptible de pacto en perjuicio del agente anterior a la extinción contractual, no podrá superar el importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años de contrato, o durante toda su duración, si fuera inferior. Para que opere, requiere que se acredite la aportación de nuevos clientes o el incremento sensible de clientela preexistente durante la vigencia del contrato, un pronóstico razonable de que el trabajo del agente continuará produciendo ventajas sustanciales al empresario tras la extinción del contrato, así como que resulte procedente la indemnización tras realizar un juicio de equidad, en el que se han de tener en cuenta la posible existencia de pactos de limitación de la competencia, la pérdida de comisiones y las demás circunstancias concurrentes.

Son muy numerosas las sentencias que hacen coincidir el importe de esta indemnización con el límite máximo previsto en el art. 28.3 LCA, pero también las que moderan dicha indemnización aplicando reducciones de naturaleza muy variada. Los principales criterios que estas últimas resoluciones tienen en cuenta serían la ausencia de pactos de limitación de la competencia tras la extinción del contrato, la contribución del empresario a la captación de clientela a través de la publicidad y/o por la notoriedad de las marcas cuyos productos o servicios se

comercializan, que el tipo de producto o servicio no sea susceptibles de nuevas adquisiciones a corto o medio plazo, la escasa duración contractual o la pérdida de clientes en la última etapa de vigencia del contrato. La concesión de una indemnización equivalente al máximo legal no debería constituir la regla general. Sin embargo, las dificultades con las que en ocasiones se encuentra el juez para argumentar la reducción de la indemnización dan lugar a que se acabe equiparando la indemnización al límite del art. 28.3 LCA. Sería conveniente que la norma del art. 28 LCA estableciese unos criterios objetivos que ayudasen al juez a cuantificar la indemnización, ampliando los criterios a tener en cuenta para realizar el juicio de equidad, más allá del posible pacto de exclusiva, y fijando diversos porcentajes para el cálculo.

En cambio, en el sector de la venta de vehículos, si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo mantiene que sigue operando la indemnización por clientela, son frecuentes las resoluciones que la excluyen por entender que no concurren los requisitos legales o que, aun reconociéndola, moderan la indemnización por debajo del límite legal, lo que viene justificado por el esfuerzo publicitario de la marca y por tratarse de venta de bienes de larga duración, entre otros criterios.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios al amparo del régimen general del Código Civil (no prevista en la LCA), los tribunales la conceden para resarcir al agente por conceptos no incluidos en la indemnización del art. 29 LCA, como el coste que conlleva la indemnización por despido a los trabajadores de los que el agente ha de prescindir tras la extinción del contrato de agencia. No obstante, a diferencia de la indemnización del art. 29 LCA, la acción en base al régimen general del Código Civil requiere acreditar que el empresario ha actuado con dolo, negligencia o morosidad o que la extinción contractual constituye una conducta abusiva.

Por otro lado, si el contrato de agencia extinguido era de duración indefinida, el agente puede también tener derecho a la indemnización por daños y perjuicios del art. 29 LCA, así como a la indemnización por incumplimiento del deber de preaviso del art. 25 LCA.

La primera permite al agente reclamar al empresario la indemnización de los daños y perjuicios que la extinción del contrato le haya ocasionado cuando, para su ejecución, ha incurrido en gastos que no ha podido amortizar durante su vigencia. Al igual que en la indemnización por clientela, la imperatividad de la norma no permite pactos en perjuicio del agente anteriores a la finalización contractual. Además de un contrato de duración indefinida, precisa que se haya producido la extinción del contrato a instancias del empresario y no debida al incumplimiento de sus obligaciones por parte del agente, así como que el agente acredite la realización de gastos de inversión o adecuación no amortizados, bien siguiendo órdenes del empresario, bien cuando, aun no existiendo instrucciones de este, la inversión fuese necesaria para acometer convenientemente el encargo. Los tribunales conceden indemnizaciones con base en el art. 29 LCA por gastos tales como material de oficina inservible (p. ej., por llevar el logotipo del empresario), gastos para adecuar

el local con los símbolos y marcas del empresario, como pintura o rótulos, letreros publicitarios pintados en vehículos, entre otros.

Por último, por lo que se refiere a la indemnización por incumplimiento por parte del empresario del plazo de preaviso de la extinción contractual que impone el art. 25 LCA, esta no se encuentra expresamente prevista en la LCA. Si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dejado claro que el incumplimiento del deber de preaviso no produce necesariamente un daño indemnizable y que, en su caso, tal daño no tiene por qué coincidir con el promedio de las remuneraciones que hubiera percibido el agente durante el tiempo cubierto por el preaviso, lo cierto es que la postura mayoritaria de los tribunales es conceder al agente por tal concepto una indemnización equivalente a la cantidad resultante de multiplicar la retribución media mensual obtenida por el agente durante los últimos cinco años de contrato (o durante toda su duración, de ser inferior) por el número de meses de preaviso omitidos. Resulta razonable indemnizar al agente, en base a un criterio objetivo, el lucro cesante ocasionado por el incumplimiento legal del deber de preaviso, como la media mensual sobre las retribuciones percibidas en el último año de contrato —o durante toda su duración, de ser inferior—.

Todas las indemnizaciones anteriores a que puede tener derecho el agente son compatibles entre sí.

El art. 31 LCA fija un plazo de prescripción de un año para la reclamación de indemnizaciones por clientela y por daños y perjuicios, acciones de las que deberán conocer los tribunales del domicilio del agente (Disposición adicional segunda LCA).

VII. BIBLIOGRAFÍA

ALONSO ESPINOSA, F. J., *Derecho Mercantil de Contratos*, Thomson Reuters, Navarra, 2011.

ALONSO SOTO, R., «Contenido del contrato de agencias», en *Estudios y Comentarios Legislativos Civitas* (BIB\2007\3417).

ARROYO APARICIO, A., *Contrato de Agencia: principios y análisis*, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019.

GADEA SOLER, E. y SACRISTÁN BERGIA, F., *El contrato de Agencia. La Ley 12/1992 en la jurisprudencia*, Ed. La Ley, Madrid, 2010.

LARA GONZÁLEZ, R., *Las causas de extinción del contrato de agencia*, Ed. Civitas, Madrid, 1998.

—, «Pacto de limitación de la competencia y extinción del contrato de agencia por incumplimiento del empresario», en CUÑAT EDO, V., MASSAGUER, J., ALONSO

- ESPINOSA, F. J., GALLEGO SÁNCHEZ, E. (dirs.), *Estudios de Derecho Mercantil. Liber Amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- LLOBREGAT HURTADO, M. L., *El Contrato de Agencia Mercantil*, Ed. J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1994.
- MARTÍNEZ SANZ, F., *La indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión*, Ed. Civitas, Madrid, 1998.
- MARTÍNEZ SANZ, F., MONTEAGUDO, M. y PALAU RAMÍREZ, F., *Comentario a la Ley sobre el Contrato de Agencia*, Ed. Civitas, Madrid, 2000.
- MOXICA ROMÁN, J., *La Ley del Contrato de Agencia*, Ed. Aranzadi, Navarra, 2001.
- ORTEGA PRIETO, E., *El Contrato de Agencia*, Ed. Deusto, Bilbao, 1993.
- PARJOLEA, A. D., «Comentario a la Sentencia del TS de 8 de octubre de 2010», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 87/2011, Ed. Civitas, 2011.
- PÉREZ CAMPOS, A. I., *Representación comercial: contrato de trabajo o agencia mercantil*, Ed. Laborum, Murcia, 2002.
- RUIZ PERIS, J. I. y MARTÍ MIRAVALLS, J. (dirs.), *Contratos de Distribución*, Ed. Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2018.
- SALAS CARCELLER, A., «Nulidad del pacto sobre importe de la indemnización a percibir por el agente en caso de terminación del contrato de agencia», *Revista Aranzadi Doctrinal* núm. 11/2011, Ed. Aranzadi, 2011.

(Trabajo recibido el 02/09/2024
y aceptado para su publicación el 04/12/2024)